

제39장

민사조정절차

제1절	총 설	610
제2절	조정절차의 개시	626
제3절	조정절차의 진행	637
제4절	조정절차의 종료	648
제5절	조정조항	666

제1절 총 설

1. 개 요

민사조정제도는 민사에 관한 분쟁에 있어서 중립적인 제3자가 당사자의 동의를 얻어 당사자가 쉽게 협상할 수 있도록 도와주는 분쟁해결방법이다. 민사조정법은, 당사자의 신청에 의하여 또는 소송사건의 조정회부에 의하여 조정담당판사나 수소법원 또는 법원에 설치된 조정위원회가 간이한 절차에 따라 분쟁당사자들로부터 각자의 주장을 듣고 관계자료를 검토한 후 여러 사정을 고려하여 그들에게 상호 양보하게 합의하도록 권유·주선함으로써 화해에 이르게 하는 제도를 마련하여 두고 있다(민조 1조, 2조, 7조). 민사조정제도는 기존 소송제도의 지연과 비용과다 그리고 일도양단적인 결론에 따른 당사자 사이의 인적 관계의 파탄 등의 폐단을 피하기 위한 것이다. 조정 절차에 의한 분쟁해결은 절차가 간이하고 비용이 저렴하며 사회 각 분야의 권위자·전문가들이 조정위원이 되어 그 전문적 지식을 활용하여, 분쟁을 타협과 양보에 의하여 인적 관계를 파괴함이 없이 신속하고 원만하게 종국적으로 해결할 수 있는 장점이 있다. 2020. 2. 4. 개정 민사조정법에서는 보다 조정이 활성화될 수 있도록 조정위원의 역할을 강화하거나(7조 6항), 조정위원에게 정기적인 교육과 연수의 기회를 제공하도록 하고(10조 4항), 조정위원으로 하여금 당사자의 권익을 보호하도록 하는 규정을 신설하였다(11조 2항). 민사조정법 개정에 따라 민사조정규칙도 2021. 10. 29. 대법원규칙 제 3002호로 일부 개정되었다.

민사조정제도의 활성화를 위하여 대법원이 제정한 예규가 ‘민사 및 가사 조정의 사무처리에 관한 예규’인데, 그 시행과 더불어 각급 법원도 조정신청의 적극적 유도, 수소법원에 의한 조정회부의 활성화, 조정전담법관의 배치, 전문조정위원의 선정 확대, 조정과 화해의 홍보물 작성 및 대외 홍보의 확대

등 조정활성화 조치를 계속하고 있다.

우리나라의 민사조정은 크게 민사조정신청에 의한 조정과 소가 제기된 이후 수소법원이 회부하는 조정으로 나누어 볼 수 있다. 조정신청은 서면 또는 구술로 할 수 있는데(민조 5조 1항) 실무상 구술로 조정신청을 하는 경우는 드물다. 또한 수소법원은 항소심판결 선고 전까지 소송이 계속 중인 사건을 결정으로 조정에 회부할 수 있다(6조).

조정사건은 조정담당판사가 처리하도록 되어 있고, 조정담당판사는 스스로 조정을 하거나 상임 조정위원 또는 조정위원회에게 조정을 하게 할 수 있다. 다만 당사자의 신청이 있을 때에는 조정위원회에서 조정을 하도록 하여야 한다(민조 7조 1항, 2항). 실무상으로는 조정신청사건 중 피신청인이 조정기일에 출석하지 않고 사실상 다툼이 없는 사건은 조정전담판사 단독으로 처리하지만, 다툼이 있는 경우는 대체로 조정위원회에서 처리하고 있다.

한편 수소법원이 스스로 조정하는 경우에는 수명법관 또는 수탁판사에게 조정을 하게 할 수 있고(민조 7조 5항), 이 경우 수명법관 또는 수탁판사는 조정담당판사와 동일한 권한을 가지므로(7조 5항) 조정장이 되어 수소법원에 직속된 조정위원회를 운영할 수 있다.

법원의 조정업무에 관련하여서는, 2002년 1월 법원행정처에서 발간한 『조정실무』가 조정절차의 법률적 해설과 사건 유형별 조정기법에 이르기까지 상세한 설명을 담고 있어서 조정실무의 지침이 되고 있다.

2. 관할 및 이송

가. 관할법원

조정사건은 ① 피신청인에 대한 민사소송법 3조부터 6조까지의 규정에 따른 보통재판적 소재지, ② 피신청인의 사무소·영업소 소재지, ③ 피신청인의 근무지, ④ 분쟁의 목적물 소재지, ⑤ 손해 발생지 등을 관할하는 지방법원, 지방법원 지원 또는 시·군법원이 관할한다(민조 3조 1항). 조정사건은 그

에 상응하는 소송사건의 전속관할법원이나 당사자 사이에 합의로 정한 법원에서 관할할 수도 있다(4조 2항). 민사조정법 3조의 해석상 문제점 및 관련 재판적 등에 관해서는 『조정실무』, 35쪽 이하 참조.

나. 이 송

조정담당판사는 사건이 그 관할에 속하지 아니한다고 인정할 때에는 결정으로 사건을 관할법원에 이송하여야 한다. 그러나 피신청인이 관할위반에 대하여 항변을 하지 아니하고 조정절차에서 진술하거나, 사건의 해결을 위하여 특히 필요하다고 인정할 때에는 그러하지 아니하다(민조 4조 1항).

조정담당판사는 사건이 그 관할에 속하는 경우라도 이송하는 것이 적절하다고 인정하면 직권 또는 당사자의 신청에 의한 결정으로 사건을 다른 관할 법원에 이송할 수 있고(민조 4조 2항), 위 이송결정에 대하여는 불복의 신청을 하지 못한다(3항). 이송신청 각하결정에 대해서도 불복하지 못한다고 해석함이 상당하다.

다. 관할법원의 지정

수개 법원의 토지관할에 관하여 의문이 있을 경우에는 관할법원의 지정은 관계법원에 공통되는 직근 상급법원이 신청에 의하여 결정으로 이를 하며, 이에 대해서는 불복신청이 금지된다(민조 39조, 비송 4조).

3. 조정기관

가. 조정담당판사

조정사건은 조정담당판사가 처리한다(민조 7조 1항). 조정담당판사는 고등법원장, 지방법원장 또는 지방법원지원장의 지정을 받아 조정사건을 담당하는 판사 또는 조정사건을 담당하는 시·군법원의 판사를 의미한다(4조 1항).

조정담당판사는 스스로 조정을 할 수 있고, 상임 조정위원 또는 조정위원

회에게 조정을 하게 할 수도 있다(민조 7조 2항 본문). 다만 당사자가 조정위원회에서 조정하여 줄 것을 신청한 때에는 조정위원회에게 이를 하게 하여야 한다(단서). 이와 같이 조정담당판사, 상임 조정위원 또는 조정위원회 어느 쪽이든 자유롭게 정하여 조정사건을 처리할 수 있고, 수소법원 스스로 조정기관이 되어 직접 조정을 할 수도 있다(3항).

조정신청된 사건 및 조정에 회부된 사건으로서 수소법원이 직접 조정하지 아니하는 사건은 조정담당판사에게 배당한다. 다만 당사자가 처음부터 조정위원회의 조정을 신청한 사건은 곧바로 조정위원회에 배당한다. 그러나 ① 조정신청사건(다만 조정신청사건 중 당사자 사이에 다툼이 심하여 즉일 조정하기가 어렵다고 판단되는 사건이나 당사자가 조정위원회의 조정을 원하는 사건은 조정위원회에 회부하여 처리한다), ② 사실관계에 관하여는 당사자 사이에 별다른 다툼이 없고 법률적 판단만이 문제 되는 사건, ③ 사건 당사자가 대부분의 조정위원들과 특수한 관계에 있거나 면식이 있기 때문에 조정위원이 자유롭게 자신의 견해를 표명하기 곤란한 사건의 경우에는 조정전담당판사가 처리함이 상당하다(조정예규 10조 1항).

조정담당판사가 스스로 조정을 하는 중에 직권 또는 당사자의 신청에 의하여 조정위원회에게 사건을 처리하게 하는 경우에는 조정담당판사가 조정장으로서 조정위원회를 구성할 조정위원을 지정하여야 한다(조정예규 7조 4항). 조정담당판사가 스스로 조정을 하거나 조정위원회에게 조정을 하도록 하는 경우 조정담당판사나 조정장은 조정위원이 분쟁해결방안을 도출하기 위하여 사건관계인의 의견을 들어 합의안을 도출하거나 그 밖에 조정사건의 처리를 위하여 필요한 사무를 수행하게 할 수 있다(민조 7조 6항).

조정담당판사는 조정절차의 대리인·보조인의 허가 및 그 허가취소권(민조규 6조 2항, 4항), 사실조사권(8조), 의견청취촉탁권(9조), 조사촉탁권(11조), 이의신청각하권(16조 1항) 등의 권한을 가진다.

법원장은 조정제도에 적극적인 관심을 가진 법관 중에서 가능한 한 2인

이상을 조정담당판사로 지정하여야 하고, 조정담당판사가 충실하게 효율적으로 조정을 할 수 있도록 가능한 한 조정사건만을 전담하여 처리하도록 하고, 법원의 사정에 따라 조정 이외의 업무를 맡게 될 경우에도 다른 업무의 종류 및 부담량을 적절히 조절하여야 한다. 법원장은 법관 개인이나 법원의 특수한 사정으로 인하여 사무분담 변경 필요가 있는 경우를 제외하고는 조정담당판사로 지정된 법관의 조정사건에 관한 사무분담이 2년 안에 변경되지 않도록 하고, 위 기간 안에 사무분담을 변경한 경우에는 지체 없이 법원행정처장에게 그 사유를 보고하여야 한다. 이 경우 지원장은 소속 법원장을 경유하여야 한다(조정예규 3조 1항 내지 4항). 조정담당판사가 다른 업무를 하게 하는 경우에는 다른 재판부에서 조정회부를 주저하게 되므로 조정전담법관을 두어야 조정회부가 활발하게 된다.

조정담당판사는 조정사건의 처리 외에도 조정위원회 구성과 조정위원회의 운영방식의 설정, 조정사건의 배당, 조정회부의 권장과 조정회부사건의 관리, 적정한 조정사무에 필요한 지원업무 지휘·감독, 조정위원 교육, 조정활성화 계획 수립과 집행, 조정사무에 관한 각종 보고, 그 밖의 조정활성화에 필요한 사무를 처리한다(조정예규 3조 5항).

나. 조정위원회

(1) 개 요

조정위원회에 의하여 조정할 사건으로는 ① 다수의 분쟁당사자 사이에 이해관계가 첨예하게 대립되어 있는 사건, ② 친족·동업자 간의 분쟁과 같이 감정 대립이 심하여 그 분쟁을 해결하는 데 법률적 지식보다는 조정위원의 경륜에 의한 설득이 필요하다고 판단되는 사건, ③ 건축공사 관련 분쟁, 의료 관련 분쟁 등과 같이 전문지식이 요구되어 전문가가 조정위원이 조정에 참여하는 것이 바람직한 사건, ④ 당사자가 조정위원회의 조정을 원하는 사건 등을 들 수 있다(조정예규 10조 2항). 조정위원회는 조정장 1인과 조정위원 2

인 이상으로 구성한다(민조 8조).

(2) 의결방법

조정위원회의 의결은 과반수의 의견에 의한다. 그러나 가부동수인 경우에는 조정장의 결정에 따른다(민조규 14조). 조정위원회의 합의는 공개하지 아니한다(15조).

(3) 직무권한

조정위원회는 당사자의 신청 또는 조정회부결정에 따른 조정사건의 조정을 담당하는데, 이 경우에는 이해관계인의 조정참가 허가(민조 16조), 피신청인 경정허가(17조 1항), 대표자선임명령(18조 3항), 조정장소 결정(19조), 조정 전 처분(21조 1항), 진술청취·사실조사(22조), 조정신청 각하결정(25조 1항), 조정을 하지 아니하는 결정(26조 1항), 조정의 불성립 처리(27조), 조정을 갈음하는 결정(30조, 32조) 등의 직무권한을 가진다(40조 1호).

또한 조정위원회는 사실조사 촉탁 등(민조규 8조), 집행절차정지, 속행명령(18조 1항, 5조 1항, 2항), 의견청취촉탁(18조 1항, 9조), 조사촉탁(18조 1항, 11조) 등의 직무권한을 가진다. 다만 조정위원회의 명령·결정·처분서 등에는 조정위원회를 대표하여 조정장이 기명·날인한다(18조 2항). 따라서 조정위원회의 조정을 갈음하는 결정에는 조정장만 기명·날인하면 된다. [전산양식 A1912] 참조.

(4) 조정장

조정담당판사가 스스로 조정을 하거나 상임 조정위원 또는 조정위원회에 계 조정을 하게 할 경우에는 조정담당판사 또는 상임 조정위원이(민조 9조 1호), 수소법원이 스스로 조정을 할 경우에는 수소법원의 재판장이(2호), 수소법원이 수명법관 또는 수탁판사로 하여금 조정을 담당하게 할 경우에는 수명법관 또는 수탁판사가(3호), 시·군법원의 경우에는 시·군법원의 판사가 조정장이 된다(4호).

조정장은 조정위원회의 조정절차를 지휘하며(민조 11조), 수수료납부명령

과 불응시의 신청서 각하명령(13조), 방청허가(20조), 조서의 일부 생략 허가(24조 단서), 조정을 갈음하는 결정에 대한 이의신청이 있는 경우 상대방에 대한 통지(34조 2항), 조정전 처분 위반자에 대한 과태료결정(42조) 등의 직무권한을 가진다(40조 2호).

또한 조정장은 조정절차의 대리인 또는 보조인에 대한 허가권 및 그 허가 취소권(민조규 18조 1항, 6조 2항, 4항), 이의신청각하권(18조 1항, 16조 1항), 조정위원 지정취소권(7조)도 가진다.

(5) 조정위원

(가) 위촉, 임기, 해촉 등

조정위원은 고등법원장, 지방법원장 또는 지방법원지원장이 학식과 덕망이 있는 사람 중에서 미리 위촉한다(민조 10조 1항 본문). 그러나 다음 사유에 해당하는 자는 조정위원으로 위촉될 수 없다. ① 피성년후견인 및 피한정후견인, ② 금고 이상의 형을 받은 자, ③ 공무원으로서 면직의 징계처분을 받고, 당해 처분일로부터 2년을 경과하지 아니한 자, ④ 변호사로서 제명의 징계처분을 받고, 당해 처분일로부터 3년을 경과하지 아니한 자, ⑤ 법무사로서 업무정지의 징계처분을 받고, 당해 처분일로부터 3년을 경과하지 아니한 자(조위규 3조 1항). 또한 다음 사유에 해당하는 자는 사건의 내용 등에 비추어 조정위원의 직무를 수행함에 있어 재판의 공정과 신뢰를 해할 우려가 없다고 판단되는 경우에 한하여 조정위원으로 위촉될 수 있다. ① 형사사건으로 공소제기되어 있는 자, ② 민사·가사사건의 당사자 또는 이해관계인, ③ 자격상실 이하의 형을 받은 자(2항).

법원장은 조정위원을 위촉함에 있어서 다음 사항을 고려하여야 한다(조정예규 4조).

① 관할구역 내에서 주로 발생하는 분쟁의 유형, 사건 수, 조정위원으로 위촉할 만한 사람의 수, 연령 및 직업분포 등 해당 지역의 실정을 감안하여 적절한 인원수의 조정위원을 위촉하여야 한다.

② 지방자치단체·교육기관·변호사회·변리사회·법무사회·의사회·건축사회·감정평가사협회 기타 적당하다고 인정되는 직능단체 또는 사회단체에 추천을 의뢰하거나 각급법원의 인터넷 홈페이지에 공모하는 등의 방법으로 사회 각계각층으로부터 광범위하게 조정위원으로 위촉할 만한 사람을 물색하도록 한다.

③ 조정위원으로 위촉할 사람에 대하여 면접과 추천자의 의견 청취 등 적절한 방법으로 조정위원으로서 충분한 자질을 갖추었는지 여부를 조사하여야 한다.

④ 변호사·법무사·공인회계사·의사·교수·건축사·감정평가사 등 다양한 분야에 관한 전문적인 지식과 경험을 가진 조정위원을 다수 위촉하여 분쟁의 적절한 해결에 실질적인 기여를 할 수 있도록 하여야 한다.

⑤ 조정위원의 임기가 만료된 경우에 조정위원의 참여도, 성실성, 조정사건 처리능력, 성품과 건강 등 여러 요소를 고려하고, 조정담당판사 또는 조정장의 의견을 참고하여 재위촉 여부를 결정한다. 다만 임기 중 조정에 전혀 참여하지 아니한 조정위원은 재위촉하지 아니한다.

한편 법원장은 노동사건의 조정을 담당할 전문가 조정위원으로 노동전문조정위원을 위촉하여야 한다. 노동전문조정위원은 정부기관·교육기관·변호사회·공인노무사회·근로자단체·사용자단체 등 노동문제와 관련된 다양한 직역 및 단체로부터의 추천 및 의견수렴을 거쳐 위촉하고, 그 수는 당해 법원의 노동사건의 수, 노동전문재판부의 수 등을 참작하여 정한다(조정예규 38조).

조정위원의 임기는 2년으로 한다. 다만 특별한 사정이 있을 때에는 임기를 2년 이내로 정하여 조정위원을 위촉할 수 있다(민조 10조 2항).

법원장은 조정위원이 조정위원규칙 3조 1항의 결격사유와 2항의 각 호에 해당하는 경우로서 조정위원의 직무를 수행함에 있어 재판의 공정과 신뢰를 해할 우려가 있는 때에는 해촉하여야 하고(조위규 4조 1항), ① 심신상의 장

애로 직무집행을 할 수 없다고 인정될 때, ② 정당한 이유 없이 법원의 조정 기일 참여요청에 2회 이상 응하지 않을 때, ③ 직무상 의무위반, 기타 조정 위원으로서 부적당한 행위가 있다고 인정될 때 ④ 그 밖에 조정위원으로서 계속 활동하기 어렵다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 경우에는 해촉할 수 있다(2항).

그 외 자세한 사항 및 임기·해촉·신분 등에 관해서는 『조정실무』, 44쪽 이하 참조. 2022. 7. 29. 일부 개정된 조정위원규칙은 조정위원에게 위촉 이후 발생한 사유에 따라 사후적으로 위임관계를 소멸하게 하는 경우 ‘위촉의 취소’가 아닌 ‘해촉’으로 변경하고, 앞서 본 바와 같이 4조 2항 4호로 일반규정을 신설하였음에 유의해야 한다.

(나) 담당업무

조정위원은 조정위원회의 구성원의 1인으로서 조정위원회에서 행하는 조정에 관여하는 것이 그 기본 업무이나, 그 밖에 조정장의 촉탁을 받아 분쟁의 해결을 위하여 사건관계인의 의견을 듣거나 조정사건의 처리를 위하여 대법원규칙이 정하는 기타 사무(예: 민조규 10조에 따른 수탁판사 지시에 따른 사실조사·의견청취 등)를 행한다(민조 10조). 또한 민사조정법 10조를 근거로 조정위원회 구성없이 조정담당판사 또는 조정장의 촉탁을 받은 조정위원 1인이 조정기일에 참여하는 방식도 실무상 이용되고 있다. 개정 민사조정법에 의하면 조정위원이 법원 외의 장소에서 조정사무를 수행하는 경우에는 미리 조정담당판사의 허가를 받아야 한다(19조 2항).

(다) 수당 등 지급

조정위원에게는 예산의 범위 안에서 대법원규칙으로 정하는 바에 따라 수당을 지급하고, 필요한 경우에는 그 밖의 여비·일당·숙박료를 지급할 수 있다(민조 12조, 조정예규 31조 참조).

(라) 개념의 구별

조정위원과 조정위원회를 구성하는 조정위원은 구별되는 개념이다.

전자는 고등법원장, 지방법원장 또는 지방법원지원장이 학식과 덕망이 있는 자로서 미리 위촉한 자를 가리킨다. 따라서 이러한 조정위원은 구체적인 사건과는 상관없이 각 법원별로 일정수의 사람이 위촉되어 있으며, 그들은 구체적인 사건에서 후술하는 조정위원회를 구성하는 조정위원으로 지정되어 조정과 관여하는 외에 단순히 조정위원의 자격으로 일반적으로 조정담당판사, 조정위원회, 지방법원 판사 등으로부터 촉탁받은 사무를 처리한다. 그러한 사무로는 사실조사(민조규 8조 3항, 10조), 의견청취(10조), 기타 의견진술(12조) 등이 있다.

후자는 구체적인 특정사건의 조정을 위하여 전술한 바와 같이 각 법원에 위촉되어 있는 조정위원들 중에서 조정장이 해당 사건의 특성과 실정에 비추어 해당 분야에 관한 전문적 식견을 가진 자라고 보아 그 사건의 조정위원으로 지정한 자를 가리킨다. 따라서 이들 조정위원회를 구성하는 조정위원은 당해 조정사건의 조정에만 관여할 뿐이며, 그 사건의 조정이 끝남과 동시에 그 지위도 소멸한다.

노동전문조정위원회를 구성함에 있어서는 조정장은 당사자가 합의에 의하여 노동전문조정위원회를 구성할 조정위원을 선정할 수 있는 기회를 부여하여야 하고, 당사자의 합의에 의하여 선정된 조정위원이 없거나 당사자의 합의에 의하여 선정된 조정위원이 조정위원회를 구성할 조정위원 수에 미달하는 경우에는 조정장이 사건의 특성 및 전문성 등을 고려하여 필요한 수의 조정위원을 지정하되, 사건에 대한 중립성 및 노사 간 형평성이 유지될 수 있도록 구성하여야 한다. 조정전담판사는 조정신청사건인 노동사건의 조정을 위해서는 노동전문재판부에 전속된 조정위원으로 노동전문조정위원회를 구성할 수 있다(조정예규 40조).

민사조정법은 10조에서 조정위원을, 10조의2에서 조정위원회를 구성하는 조정위원을 규정하고 있다.

(6) 조정위원회의 운영방식

조정위원회를 소집했다 하더라도 조정장이 일방적으로 사건의 해결을 시도하면 조정위원들의 참여 의욕이 떨어지고 조정위원회의 소집에 소극적일 우려가 있다. 조정위원에게 조정기일 이전에 소장·답변서·준비서면의 복사본을 송부하여 사건의 내용을 파악할 수 있도록 하고, 조정을 실시할 때에도 조정장은 조정위원에게 많은 심문 기회를 부여하는 등 조정에 적극적으로 참여하도록 유도하여야 한다. 조정위원회가 조정을 함에 있어 조정장은 필요한 쟁점의 정리나 법률적인 조언을 하되, 사정의 청취, 당사자에 대한 설득, 타협안의 제시 등을 가급적 조정위원에게 담당하도록 하는 것이 바람직하다(조정예규 12조 3항).

특히 노동전문조정위원회의 조정장은 노동전문조정위원회가 조정을 갈음하는 결정에 관하여 의결하지 못하여 조정장이 결정하는 경우에도 조정위원들의 의견을 참작하여 그 내용을 결정하여야 한다(조정예규 42조).

더 자세한 조정위원회의 운영방식 및 주심 조정위원제도에 관해서는 『조정실무』, 53쪽 이하 참조.

다. 상임 조정위원

상임 조정위원 제도는 변호사 자격이 있고 일정한 경력을 가진 사람을 상임 조정위원으로 위촉하여(민조 10조 1항 단서) 조정장으로서 조정사건을 처리할 수 있도록 함으로써 조정을 활성화하여 분쟁을 신속하고 원만하게 해결하려는 것이다.

법원행정처장은 고등법원, 지방법원 및 지방법원의 지원 소속 상임 조정위원을 위촉하여 민사조정법에 따른 조정에 관한 사무를 처리하게 할 수 있는데(조위규 2조의2 1항), 위촉 시에 해당 상임 조정위원이 직무를 수행할 법원을 지정한다(조정예규 45조).

상임 조정위원은 ① 통산하여 10년 이상, 판사·검사·변호사의 직에 있거

나 변호사의 자격이 있는 사람으로서 국가기관, 지방자치단체, 국·공영기업체, 정부투자기관 그 밖의 법인에서 법률에 관한 사무에 종사하거나 변호사의 자격이 있는 사람으로서 공인된 대학의 법률학 조교수 이상의 직에 있던 사람 또는 ② 변호사 자격이 있는 사람으로서 민사조정위원 또는 가사조정위원으로 3년 이상 활동한 사람 중에서 위촉한다(조위규 2조의2 2항).

상임 조정위원은 법원행정처장의 허가 없이 다른 직무를 겸할 수 없고, 민사조정법에 따른 조정에 관한 사무 이외에 변호사 직무를 행할 수 없으며(다만 조위규 2조의3 2항 단서 각 호에 해당하는 사건에 관하여는 법원행정처장의 허가를 받아 변호사 직무를 행할 수 있다), 법관의 제척·기피 및 회피에 관한 민사소송법의 규정이 준용된다(2조의3 1항, 2항, 3항).

상임 조정위원은 조정장이 될 수 있고(민조 9조 1호), 조정담당판사와 동일한 권한을 갖고(7조 4항) 상시적으로 조정업무를 담당하게 되며, 실질적으로 공무를 수행하므로 그 업무에 관하여 공무원과 같은 책임을 부과할 필요가 있으므로 형법상 수뢰죄 등의 벌칙을 적용할 때에는 공무원으로 본다(40조의2).

라. 수소법원

수소법원은 특별한 사정이 없는 한 다툼 있는 사건에 대하여 소송절차의 어느 단계에서든 1회 이상 조정에 회부하는 것을 원칙으로 하며, 변론종결 후에도 사건을 조정에 회부할 수 있다. 수소법원이 조정회부사건을 직접 처리하는 경우 조정이 성립하지 않는 때에는 적극적으로 조정을 갈음하는 결정을 하여 사건을 적정하게 해결하도록 한다(조정예규 11조 1항, 3항).

수소법원이 조정에 회부한 사건을 스스로 처리하는 경우, 수소법원은 조정담당판사와 동일한 권한을 가진다(민조 7조 4항). 따라서 합의재판부인 수소법원이 조정을 할 때는 원칙적으로 법관 3인이 모두 관여하여야 하고, 조정을 갈음하는 결정도 3인의 이름으로 하여야 한다. 다만 합의부의 경우에 구성원 1인을 수명법관으로 지정하여 조정을 하는 경우가 많은데, 수명법관

은 조정담당판사와 동일한 권한을 가지므로(5항), 조정을 갈음하는 결정도 수명법관 단독으로 할 수 있다.

다음과 같은 유형의 사건은 수소법원이 직접 처리함이 상당하다(조정예규 10조 3항).

- ① 교통사고, 산업재해사고로 인한 손해배상사건
- ② 사실관계에 대한 증거조사가 충분히 이루어져 수소법원이 사실관계 및 이에 대한 법률적 평가를 할 수 있는 단계에 있는 사건
- ③ 당사자가 사건의 신속한 해결을 원하고 비교적 조정이 쉽게 이루어질 것으로 예상되는 사건

4. 조정당사자

가. 당사자적격 및 호칭

조정당사자적격이 있는 자란 해당 조정사건의 내용으로 되어 있는 구체적 인 분쟁을 실질적으로 해결할 수 있는 지위에 있는 자 또는 그 해결에 관하여 정당한 이익을 가진 자이다. 우선, 해당 사건의 목적으로 되어 있는 권리 또는 법률관계에 관하여 관리처분권을 가지는 자는 당사자적격이 있다. 당사자적격이 없는 자의 합의로 성립한 조정의 효력은 당사자적격을 가지는 자에게 미치지 않는다.

당사자가 조정신청을 한 경우에는 조정당사자를 각 조정신청인과 피신청인으로 호칭한다. 반면, 조정에 회부한 사건은 수소법원이 처리하는 경우는 물론 조정담당판사나 상임 조정위원, 조정위원회가 처리하는 경우에도 원고와 피고로 호칭한다.

나. 피신청인의 경정

신청인이 피신청인을 잘못 지정한 것이 명백한 경우에는 조정담당판사, 상임 조정위원 또는 조정위원회는 신청인의 신청을 받아 결정으로 피신청인

의 경정을 허가할 수 있다(민조 17조 1항, 40조).

위 경정허가결정이 있는 경우 새로운 피신청인에 대한 조정신청은 위 경정신청이 있을 때에 한 것으로 본다(민조 17조 2항). 그리고 종전의 피신청인에 대한 조정신청은 경정신청이 있을 때에 취하된 것으로 본다(3항).

수소법원이 조정에 회부한 사건의 조정절차에서 원고가 피고경정신청을 한 경우의 처리 및 조정절차의 승계문제에 관해서는 『조정실무』, 60쪽 이하 참조.

다. 대표당사자의 선임

조정에서는 당사자 자신이 분쟁해결에 주체적으로 관여하는 것이 원칙이므로, 민사조정법에는 민사소송법상의 선정당사자에 관한 규정이 준용되지 않는다(민조 38조 1항). 민사조정법은 그 대신 대표당사자제도를 채택하고 있다.

조정절차에서 공동의 이해관계가 있는 다수의 당사자는 그중 한 사람 또는 여러 사람을 대표당사자로 선임할 수 있다(민조 18조 1항). 이 선임은 서면으로 증명하여야 하며(2항), 조정담당판사나 상임 조정위원, 조정위원회는 필요하다고 인정하면 당사자에게 대표당사자를 선임할 것을 명할 수 있다(3항).

대표당사자는 각자 조정절차에 관한 모든 행위를 할 수 있는 것이 원칙이나, 다만 자신을 선임한 다른 당사자를 위한 조정조항안의 수락, 조정신청의 취하, 조정을 갈음하는 결정에 관계되는 행위, 대리인의 선임은 하지 못한다(민조 18조 4항). 대표당사자가 선임된 경우에는 대표당사자 외의 나머지 당사자에게는 조정기일을 통지하지 아니할 수 있다(5항).

대표당사자는 이를 선임한 당사자들을 대표하여 조정기일의 통지를 받고, 조정기일에 출석할 수 있는 등의 권한이 있으나, 분쟁 해결에 관한 종국적 행위를 할 권한은 없는 점을 주의하여야 한다. 이 점에 관하여, 굳이 조정절차에서 선정당사자의 선정을 금할 필요는 없다는 비판도 제기되고 있다. 조

정절차에서 선정당사자의 지위와 관련하여 민사조정법 18조의 문맥상 대표 당사자는 조정절차에서 선정된 대표당사자에게만 적용되는 것으로 해석되고, 민사조정법 38조도 조정절차에서 새로 선정당사자를 선정하는 것이 허용되지 않는다는 취지일 뿐이므로 수소법원에서 이미 선정당사자가 선정된 경우에는 조정에 회부되더라도 그 선정당사자가 그대로 조정절차의 당사자가 되고 나아가 그 조정절차에서 조정성립 등 종국적 행위를 포함하여 모든 행위를 할 수 있다고 해석하는 것이 실무이다. 수소법원에서 회부된 조정사건에 있어서, 이미 선정되어 있던 선정당사자가 조정절차상 갖는 지위에 관한 구체적인 내용은 『조정실무』, 63쪽 이하 참조.

라. 이해관계인의 참가

조정절차에서도 조정참가인제도가 있는바 조정의 결과에 관하여 이해관계가 있는 자는 조정담당판사나 상임 조정위원, 조정위원회의 허가를 얻어 조정에 참가할 수 있다(민조 16조 1항). 또 조정담당판사나 상임 조정위원, 조정위원회가 필요하다고 인정하면 직권으로 조정의 결과에 관하여 이해관계가 있는 자를 조정에 참가하게 할 수도 있다(2항).

이해관계인의 참가의 요건 및 절차 등 자세한 내용은 『조정실무』, 65쪽 이하 참조.

이와 관련하여, 수소법원의 조정회부사건에서 보조참가인이 별도의 참가 허가결정 없이 자동적으로 조정참가인이 될 수 있는지 문제 되는데, 별도의 결정이 있어야 한다는 반대견해도 있으나, 소송대리인의 경우를 유추하여 별도의 허가결정 없이도 조정참가인의 지위를 취득하게 되는 것으로 보아도 무방하다.

마. 조정대리

조정사건도 단독사건이고, 민사조정법에서 민사소송법 87조(소송대리인의

자격), 88조(소송대리인의 자격의 예외)를 준용하고 있지 아니하므로 조정절차에서 대리인으로 될 수 있는 자의 자격에 아무런 제한이 없다(민조규 6조 2항). 따라서 민사소송절차와 달리 합의사건이나 항소사건, 소송목적의 값이 1억 원을 초과하는 단독사건에서도 당사자와 밀접한 생활관계를 맺고 있고 일정한 범위안의 친족관계에 있는 사람 또는 당사자와 고용계약 등으로 그 사건에 관한 통상사무를 처리·보조하는 등 일정한 관계에 있는 사람이 조정담당판사, 상임 조정위원 또는 조정장의 허가를 얻은 때에는 변호사가 아닌 자라도 조정당사자를 대리할 수 있다(민조 38조 1항, 7조 4항, 민소 87조, 88조, 민조규 6조 2항 본문, 18조 1항). 이는 자율적 분쟁해결제도인 조정절차에서 대리인이나 보조인이 당사자를 대신하여 사실관계나 이해관계를 잘 설명해줄 수 있는 것으로 충분하다는 취지로 변호사 선임에 대한 금전적 부담을 줄여 당초 조정제도의 취지에 부합하도록 함이다.

조정사건이 소액사건에 해당하는 경우에는 소액사건심판법 8조를 준용하여 당사자의 배우자·직계혈족 또는 형제자매는 조정담당판사, 상임 조정위원이나 조정장의 허가 없이도 조정사건의 대리인이 될 수 있다(민조규 6조 2항 단서).

조정당사자가 제한능력자이거나 의사무능력자인 경우에는 특별대리인의 선임에 관한 민사소송법 62조, 62조의2 규정이 준용된다(민조 38조 1항).

소송사건이 조정에 회부된 경우, 소송대리인이 조정에 관하여도 당사자를 대리할 수 있으나, 조정에 관한 권한이 있음을 서면으로 증명하여야 한다(민조규 6조 3항). 이는 소송사건이 조정에 회부된 경우 조정대리에 관한 위임이나 허가를 새로 받아야 하는 절차상의 번거로움을 해소하고 그로 인한 절차의 지연을 방지하기 위함이다. 따라서 변호사 아닌 자에 대한 소송절차에서의 대리허가 역시 조정절차에서의 대리허가로 유효하고, 민사조정규칙 6조 4항은 조정담당판사는 언제든지 변호사 아닌 자에 대한 조정대리의 허가를 취소할 수 있다고 규정하고 있으므로, 소송절차에서 대리인으로 허가된 자

에 대하여 조정회부 후에 조정담당판사가 대리허가를 취소할 수도 있다(재민 95-1민사조정절차에 관련된 여러 의문점에 대한 검토의견 2항).

한편 조정절차는 원칙적으로 비송사건절차법의 적용을 받는 점에서(민조 39조) 조정절차와 소송절차는 준별되므로, 조정절차에서의 대리인이 소송절차에서도 대리할 수 있다는 명문의 규정이 없는 현행법상 조정절차에서 조정담당판사의 허가를 얻어 대리인이 된 자는 소송으로 이행되거나 소송으로 복귀한 경우에 대리인의 자격이 상실된다고 보아야 한다(재민 95-1민사조정절차에 관련된 여러 의문점에 대한 검토의견 2항).

대리권의 흠결이 있는 자가 조정을 갈음하는 결정에 관한 이의신청을 한 후 당사자 본인이나 보정된 대리인이 이의신청 행위를 추인하는 경우에는 대리권의 흠결이 있는 자의 이의신청은 그 행위 시에 소급하여 효력을 갖게 된다(대법원 2023. 7. 13. 선고 2023다225146 판결).

제2절 조정절차의 개시

1. 조정신청에 의한 개시

민사에 관한 분쟁의 당사자는 서면 또는 구술로 법원에 조정을 신청할 수 있다(민조 2조, 5조 1항).

가. 신청방식

서면으로 신청하는 경우, 조정신청서에는 당사자, 대리인, 신청취지, 분쟁의 내용을 명확히 기재하여야 한다(민조규 2조 1항 전단). 증거서류가 있는 때에는 신청과 동시에 이를 제출하여야 하며(후단), 피신청인의 수에 상응하는 신청서 부본을 제출하여야 한다(2항).

조정을 구술로 신청하는 경우에는 법원서기관, 법원사무관, 법원주사 또는

법원주사보등(‘법원사무관등’)의 앞에서 그 신청을 진술하여야 한다(민조 5조 2항). 조정신청을 구술로 진술할 때에는 법원사무관등은 조정신청조서를 작성하고, 이에 기명날인하여야 한다(3항).

조정신청조서에도 당사자, 대리인, 신청취지, 분쟁내용을 명확히 기재하여야 한다(민조규 2조 1항 전단). 증거서류가 있는 경우에는 신청과 동시에 이를 제출하여야 한다(후단). 이때에는 서면신청의 경우와는 달리 신청서 부분은 있을 수 없으므로 제출을 요하지 아니한다.

나. 수수료 등 납부

조정신청을 할 때에는 수수료를 납부하여야 하는데(민조 5조 4항), 그 수수료는 민사소송 등 인지법 2조에 따라 산출한 금액의 10분의 1로 한다(민조규 3조 1항 본문). 다만 ‘민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 법률’ 8조에 따라 등록사용자로서 전산정보처리시스템을 이용한 민사소송 등의 진행에 동의한 자가 조정신청서를 전자문서로 제출하는 경우의 수수료는 본문에 따라 산출한 금액의 10분의 9로 한다(3조 1항 단서). 민사조정규칙 3조 1항 본문에 따른 수수료가 1천 원 미만이면 1천 원으로 하고, 위 1항 본문 또는 단서에 따른 수수료 중 100원 미만은 계산하지 아니한다(2항). 수수료는 인지로 납부함이 원칙이나, 민사소송 등 인지규칙에서 정하는 바에 의하여 현금이나 신용카드·직불카드 등으로 납부할 수도 있다(4항).

민사조정절차상의 그 밖의 신청수수료는 그 성질에 반하지 아니하는 한 민사소송 등 인지법을 준용한다(민조규 3조 3항).

위 수수료 이외의 비용, 즉 사실조사·기일통지·고지 기타 조정절차 비용의 예납에 관하여는 민사소송법 116조(비용예납명령 등), 민사소송규칙 19조(예납의무자), 20조(예납불이행시의 국고대납)의 규정을 준용하므로(민조규 13조 1항), 대체로 통상의 민사소송의 경우의 비용예납절차와 유사하다. 송달료는 당사자 1인당 5회분을 예납받는다.

당사자 등이 예납하여야 할 절차비용의 범위와 액수에 관해서는 민사소송비용법 및 민사소송비용규칙을 준용한다(민조규 13조 2항).

다. 신청의 효력

조정신청은 시효중단의 효력이 있다(민조 35조 1항). 그러나 조정신청이 취하된 때, 조정신청이 취하간주된 때(31조 2항)는 1개월 이내에 소를 제기하지 아니하면 시효중단의 효력이 없다(35조 2항).

라. 접 수

조정신청이 있으면 사건부호인 ‘머’를 붙이며 민사조정사건으로 전산입력하고 조정사건기록표지[전산양식 A1013]를 붙여 기록을 조제한다.

2. 독촉절차에서의 조정이행신청에 의한 개시

독촉절차에서 채무자가 지급명령에 대하여 적법한 이의신청을 하여 독촉법원이 인지보정을 명한 경우 채권자가 인지를 보정하는 대신 인지보정기간 내에 조정으로의 이행을 신청할 수 있다(민조 5조의2 1항).

조정이행신청의 방식 및 절차 등에 관하여는 제37장(독촉절차) 참조.

3. 조정회부에 의한 개시

가. 소송계속 중 조정회부

법원은 특별한 사정이 없는 한 소송이 계속 중인 사건을 조정에 회부하여 당사자 사이의 상호 이해와 양보를 바탕으로 분쟁이 원만하게 해결되도록 노력하여야 한다(조정예규 2조 1항). 따라서 소장심사, 답변서 제출, 재판장의 최초 기록검토, 쟁점정리, 변론기일 등 소송절차의 어느 단계에서든 다툼이 있는 사건의 경우에는 화해권고결정을 하거나 조정에 회부하여 분쟁을 해결하는 것이 권장된다.

쟁점정리 단계, 증거조사 단계, 판결선고 단계 중 어느 때에 조정에 회부하는 것이 적절한지에 관해서는 『조정실무』, 77쪽 이하 참조.

민사조정법 2조는 ‘민사에 관한 분쟁’을 조정대상으로 하고 있는데, 청구이의의 소, 제3자의이의 소, 가압류이의 등 집행관계소송도 민사에 관한 분쟁임이 분명하므로 민사조정의 대상이 된다.

다만 조정은 대체로 쌍방의 양보를 전제로 분쟁을 해결하는 것이어서 조정내용은 당사자가 자유로이 처분할 수 있는 권리에 관한 것이어야 하고, 강제집행을 허용하지 아니한다든가 기존의 강제집행을 취소 또는 인가하는 등의 권한은 법원에게 있고 당사자에게 있는 것이 아니므로 강제집행소송의 판결주문과 같은 내용의 조정을 하는 것은 불가능하다. 집행관계소송의 전제가 된 권리관계에 대하여는 조정을 할 수 있다. 청구이의사건에 있어서 집행권원에 표시된 실체법상의 권리관계의 존부를 확인한다든가, 피신청인으로부터 일정금원을 지급받고 강제집행신청을 취하기로 하는 등의 합의를 포함하는 조항으로 조정을 성립시킬 수 있다(재민95-1민사조정절차에 관련된 여러 의문점에 대한 검토의견 1항). 그러나 형성소송인 청구이의의 소는 집행권원이 가지는 집행력의 배제를 목적으로 하는 것으로서 집행권원의 원인이 된 실체법상 권리관계에 기판력이 미치지 않고, 형성판결의 효력을 개인 사이의 합의로 창설할 수는 없으므로, 형성소송의 판결과 같은 내용으로 조정이 이루어지더라도 판결을 받은 것과 같은 효력은 생기지 않는다(대법원 2023. 11. 9. 선고 2023다256577 판결의 취지 참조).

편면적 대세효가 있어 당사자 외의 제3자에게도 효력이 미치는 주주총회 결의의 부존재·무효확인 소송이나 결의취소소송 등 회사관계소송에서도 청구 인낙이나 청구를 인용하는 내용을 포함하는 조정은 불가능하다(대법원 2004. 9. 24. 선고 2004다28047 판결).

교통사고 및 산재사고 손해배상사건에 대하여 전담재판부가 있는 경우에는 예외적인 경우를 제외하고는 전문성을 고려하여 수소법원이 직접 조정하

는 것이 바람직하다.

나. 조정회부의 절차 및 접수방식

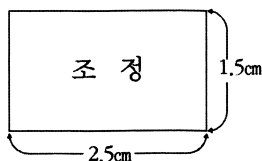
(1) 조정담당판사의 조정에 회부할 경우

수소법원이 조정회부결정을 함에 있어서는 변론기일 전이라도 법정 외에서 조정회부결정서[전산양식 A1900]를 작성하고 이를 당사자에게 송달함과 동시에 사건기록을 곧바로 조정담당판사에게 송부하는 것이 소요시간 단축을 위하여 바람직하다. 통상은 변론기일에 조정에 회부한다는 결정을 고지하고 변론조서에 그 취지를 기재한다. 조서에 기재하는 조정회부결정 양식은 [전산양식 A1901]과 같다.

수소법원이 조정회부결정을 한 때에는 법원사무관등은 조정회부로 전산입력을 하고, 조정회부결정일부터 3일 이내에 기록송부서에 의하여 사건기록을 조정담당판사에게 송부하여야 한다(조정예규 21조 1항). 수소법원이 변론기일에 조정회부결정을 하는 경우에 당사자 쌍방이 출석한 때에는 재판장은 조정담당판사로부터 미리 통보받은 기일 중 적당한 기일을 당사자에게 알려 주고 그 날 출석할 것을 권고하여야 하는데, 이렇게 당사자에게 출석을 권고한 때에는 법원사무관등은 그 기일을 기록송부서의 ‘송부사유’란에 기재하여야 한다(2항)[예: 조정회부(출석권고일 20○○. ○. ○. 10:00)]. 이와 같이 사건기록을 송부할 때에는 소송절차의 종결에 따른 공람절차를 밟지 아니한다(30조 1항).

접수담당 법원사무관등은 조정담당판사에게 송부된 사건의 기록송부서에 접수인을 찍고 민사조정사건으로 전산입력하여 등재하고 조정사건번호를 부여하여 배당절차를 밟는다. 수소법원 조정회부사건에 대하여는 조정사건기록표지를 별도로 작성하지 아니하고, 이미 붙어 있는 소송사건기록표지를 그대로 사용하되, 기존의 소송사건번호 밑에 조정사건번호를 병기하고, 기록표지의 좌측 상단에 아래와 같은 고무인을 주인(朱印)하여야 한다(조정예규

21조 3항, 4항).



한편 수소법원이 사건을 조정에 회부할 때에 사안이 복잡하여 그 개요를 적시할 필요가 있거나 수소법원의 의견을 제시하고자 할 경우에는 소송의 진행경과, 조정방향에 대한 의견 등을 기재한 **조정회부 의견서**[전산양식 A1902]를 조정담당판사에게 송부할 수 있다(조정예규 11조 2항).

위와 같이 조정회부 의견서를 따로 작성·송부하지 않더라도 사안에 따라 필요한 경우 수소법원의 의견을 직접 전달할 수 있고, 기록의 양이 많고 사건 내용의 파악에 많은 시간과 노력이 필요한 경우에는 조정담당판사에게 구두로 사건의 개요를 설명하여 주거나, 사건 메모지를 복사해서 직접 전달하는 것도 고려해 볼 수 있다.

수소법원이 조정담당판사에게 조정회부사건을 보내면서 조정위원회 조정에 회부한다고 결정을 고지하고 변론조서에 그와 같이 기재하는 예도 있으나, 조정위원회 조정에 회부할지의 여부는 조정담당판사가 결정하므로, 수소법원 조정에 회부하지 않는 경우, ‘조정에 회부한다.’는 취지로만 결정하여야 한다. 다만 조정위원회의 조정에 회부할 것을 희망하는 의견을 조정사건 개요서에 기재하여 송부할 수는 있다. 더 자세한 것은 『조정실무』, 50쪽 참조.

(2) 수소법원이 스스로 조정회부사건을 처리하는 경우

수소법원이 조정에 회부한 사건을 스스로 처리하는 경우에는 변론조서 또는 조정회부결정서에 그 취지를 기재한다(조정예규 18조).

[기재례]

- ① 변론(준비기일)조서
이 사건을 조정에 회부할 것을 결정고지(수소법원 처리).
- ② 결정서
이 사건을 조정에 회부한다(수소법원 처리).

수소법원이 조정에 회부한 사건을 스스로 처리하기로 하면서 동시에 조정위원회 조정 회부 및 조정위원 지정까지 하는 조정위원회 회부 및 조정위원 지정 결정서 양식은 [전산양식 A1900-1]과 같다.

변론기일에 조정회부결정을 하는 경우에 당사자 쌍방이 출석한 때에는 그 기일에 바로 조정을 하거나 즉시 조정기일을 지정하여 고지하여야 한다(조정예규 13조 3항).

수소법원 조정회부사건을 수소법원이 스스로 조정하거나 수소법원의 재판장 또는 수명법관이 조정장인 조정위원회에서 조정하는 경우에는 조정담당판사의 조정에 회부하는 경우처럼 사건번호 부여 등 접수절차를 밟을 필요가 없다(조정예규 21조 5항). 조정사건이 소송으로 복귀하거나 복귀한 후에 조정을 갈음하는 결정에 대한 이의신청이 취하되거나 또는 이의신청에 대한 각하결정이 확정되어 사건기록을 송부 받은 때에도 별도의 접수절차를 밟지 아니한다(29조).

위와 같은 접수절차의 특례는 수소법원이 조정에 회부한 사건을 직접 조정하는 경우뿐만 아니라, 수소법원 직속 조정위원회가 조정하는 경우에도 마찬가지로 적용된다는 것을 유의할 필요가 있다(재판사무규 22조의2 참조).

4. 조정절차 개시의 준비

가. 수수료 납부 심사

접수담당 법원사무관등은 신청인이 민사조정규칙 3조에서 정한 조정수수를 납부하지 아니한 때, 즉시 소정의 인지를 붙이지 아니한 때에는 보정을

권고하고, 신청인이 보정권고에 따르지 않을 경우 조정담당판사는 적절한 기간을 정하여 그 기간 내에 낼 것을 명하여야 하며(민조 13조 1항), 신청인이 이 명령을 이행하지 아니하면 조정담당판사는 명령으로 신청서를 각하하여야 하고(2항), 이 각하명령에 대하여는 신청인이 즉시항고할 수 있다(3항).

나. 조정신청서 부분 등 송달

조정신청서 부분이나 구술조정신청조서 등본은 지체 없이 피신청인에게 송달하여야 한다(민조 14조).

다. 조정기일

(1) 통지와 그 방법

조정기일은 당사자에게 통지하여야 한다(민조 15조 1항). 기일통지는 조정기일통지서[전산양식 A1903]를 송달하는 방법이나 그 밖의 적절한 방법으로 할 수 있다(2항). 양쪽 당사자가 법원에 출석하여 조정신청을 하는 경우에는 특별한 사정이 없으면 그 신청일을 조정기일로 한다(3항). 이는 당사자 쌍방이 법원에 출석하여 조정을 신청하는 경우 따로 조정기일을 정하여 돌려보내지 말고 신청 당일에 조정기일을 열라는 취지이다. 물론 조정을 담당할 판사가 없는 등 법원별로 특별한 사정이 있는 경우는 예외이나, 그렇지 않은 한 곧바로 조정기일을 열고 조정을 함으로써 국민들에게 보다 법원의 조정에 친숙할 수 있게 유도할 수 있다. 소송사건을 조정에 회부한 수소법원이 조정사건을 스스로 처리하기로 한 경우에는 조정회부결정을 한 그 기일에 바로 조정을 하거나, 아니면 즉시 조정기일을 지정·고지하여야 한다(조정에 규 13조 2항 단서).

조정담당판사 또는 조정장은 가능한 한 미리 특정한 요일을 조정기일로 정하여 다른 재판부와 관계직원에게 통보하여야 한다. 수소법원이 변론기일에 조정회부결정을 하는 경우에 당사자 쌍방이 그 기일에 출석한 때에는 재

판장은 위와 같이 통보받은 기일 중 적당하다고 인정되는 기일을 당사자에게 알려 주고 그 날 출석할 것을 권고하여야 한다(조정예규 13조 1항, 2항).

이에 따라 재판장이 권고한 날에 당사자 쌍방이 출석한 때에는 그 날 조정기일을 열고, 그 사건의 당사자 쌍방 또는 일방이 출석하지 아니한 때에는 조정기일을 지정하여 통지하여야 한다(조정예규 13조 3항).

1차 조정기일의 통지가 당사자 쌍방에게 이루어진 후 절차가 속행되었다가 조정속행기일의 통지가 불가능하게 된 경우 조정신청을 각하할 수 있다(민조 25조).

수소법원이 조정에 회부한 사건에 있어서, 당사자의 일방 또는 쌍방에 대하여 공시송달에 의하지 아니하고는 기일을 통지할 수 없는 때에는 조정절차를 종결하고 사건을 수소법원에 다시 회부하여야 한다(조정예규 25조 3항 1호). 이 경우 조정기관의 법원사무관등은 기록송부서에 의하여 사건기록을 수소법원에 송부하여야 한다.

(2) 당사자의 출석의무 등

위 기일통지를 받은 당사자는 기일에 본인이 출석하여야 하나, 특별한 사정이 있는 경우에는 대리인을 출석시키거나, 보조인을 동반할 수 있다(민조 규 6조 1항).

라. 조정 전의 처분

조정담당판사는 조정을 위하여 특히 필요하다고 인정하면 당사자의 신청을 받아 상대방과 그 밖의 사건관계인에게 조정 전의 처분으로서 현상을 변경하거나 물건을 처분하는 행위의 금지나 그 밖에 조정의 내용이 되는 사항의 실현을 불가능하게 하거나 현저히 곤란하게 하는 행위의 배제를 명할 수 있으나(민조 21조 1항), 민사소송법상의 보전처분과는 달리 집행력은 없다(4항).

조정담당판사는 당사자나 참가인이 조정 전의 처분에 따르지 아니하면 직권으로 500만 원 이하의 과태료를 부과할 수 있는데(민조 42조 1항), 조정 전

의 처분을 할 때에는 이와 같은 제재를 고지하여야 한다(21조 2항). 조정 전의 처분에 비록 집행력이 없지만 이러한 과태료의 제재를 통하여 그 처분내용의 실현을 간접적으로 강제하는 것이다.

과태료재판절차 및 그 집행절차에 관해서는 준용규정이 없기는 하나, 민사조정법 42조 2항의 규정 취지로 보아 비송사건절차법 248조(과태료 재판절차), 249조(과태료 재판집행), 250조(약식재판)가 준용되는 것으로 해석된다. 그러나 248조, 250조 중 검사에 관한 규정은 적용하지 아니한다(민조 42조 2항).

5. 조정절차의 개시와 소송절차 및 집행절차

가. 조정절차와 소송절차의 관계

(1) 조정과 소송 양자 계속의 경우

조정신청이 먼저 있는 사건에 관하여 소송이 계속되게 된 때에는, 그 수소법원은 결정으로 조정이 종료될 때까지 소송절차를 중지할 수 있고(민조규 4조 1항), 이 중지결정에 대하여는 불복하지 못한다(6항).

(2) 조정회부의 경우

소송사건이 조정에 회부된 때에는 그 조정절차가 종료될 때까지 소송절차는 중지한다(민조규 4조 2항).

수소법원이 사건을 조정에 회부한 이후에 당사자가 제출한 준비서면, 청구취지변경신청서, 반소장 등은 조정절차를 위하여 제출한 것으로 보아서 처리하여야 한다. 즉 조정절차가 기본적으로 직권주의의 적용을 받는 비송절차의 성격을 갖고 있는 점에 비추어 보면, 준비서면, 청구취지변경신청서, 반소장 등이 제출되면 그에 기초하여 조정을 진행하면 되는 것이고 반드시 조정기일에서 이를 진술시켜야 하는 것은 아니다. 다만 조정조서 등에서 청구의 표시를 적을 때에는 당사자의 명시적인 반대가 있는 경우를 제외하고는, 청구취지·청구원인 변경신청서의 진술 여부와 관계없이 변경된 청구취

지와 청구원인을 기재하여야 한다.

그러나 위 준비서면 등을 진술시킨 경우에도 민사조정법 23조는 조정절차에서의 진술은 민사소송에서 원용하지 못한다고 규정하고, 조정절차와 소송절차는 준별되므로 소송복귀 후 수소법원에서 다시 진술시켜야 한다(재민95-1 민사조정절차에 관련된 여러 의문점에 대한 검토의견 3항).

(3) 조정회부 후에 청구가 확장된 경우의 인지액

직권으로 조정에 회부된 사건의 진행 중에 청구취지확장신청서가 제출된 경우에 확장청구부분에 대하여 조정회부 전에 청구확장된 것과 같이 민사소송 등 인지법 5조 소정의 인지를 붙이게 하여야 하는지 아니면 조정신청사건에 준하는 것으로 보아 인지액의 1/10을 수수료로 납부하게 하면 되는지에 관하여 의문이 있었는데, 조정기일에 청구취지를 확장하는 이상 신청사건에 준하여 일단 소송인지액의 1/10의 수수료를 납부케 한 후 조정불성립 등으로 사건이 소송절차로 복귀되면 민사조정법 36조 2항을 준용하여 원래 붙여야 할 인지액에서 청구확장 시에 붙인 인지액을 뺀 나머지 금액 상당의 인지를 보정하도록 하는 것이 타당하다(재민95-1 민사조정절차에 관련된 여러 의문점에 대한 검토의견 4항).

나. 민사집행절차의 정지

조정담당판사는 분쟁의 실정에 의하여 사건을 조정에 의하여 해결하는 것이 상당하다고 인정되는 경우로서 조정의 성립을 불가능하게 하거나 또는 현저히 곤란하게 할 우려가 있는 때에는 신청에 의하여 담보를 제공하게 하거나 또는 제공하게 하지 아니하고 조정이 종료될 때까지 조정의 목적이 된 권리에 관한 집행절차의 정지를 명할 수 있다(민조규 5조 1항 본문). 다만 그 집행절차가 법원의 재판·조서, 기타 서면의 기재에 기한 것이면 조정담당판사가 이를 정지하지 못한다(단서). 따라서 집행정지 대상의 집행권원은 공정증서 등이 된다.

조정담당판사는 위 집행정지명령 후에 필요하다고 인정하는 경우에 신청에 의하여 담보를 제공하게 하거나 제공하게 하지 아니하고 속행명령을 할 수도 있고(민조규 5조 2항), 위 집행정지 또는 속행의 신청을 함에는 그 이유를 소명하여야 한다(3항).

민사소송법 122조(담보제공방식), 123조(담보물에 대한 피고의 권리), 125조(담보취소), 126조(담보물변경)의 규정은 위 각 담보에 이를 준용한다(민조규 5조 4항).

위 정지결정 또는 속행결정에 대하여는 당사자는 즉시항고할 수 있다(민조규 5조 5항). 위 집행정지신청서 또는 집행속행신청서의 서식은 민사집행법상의 집행절차에 있어서의 각 그것에 준하여 작성하면 되고, 위 즉시항고장 역시 민사집행절차 상의 즉시항고장 서식에 준해서 작성하면 된다.

제3절 조정절차의 진행

1. 총 설

가. 조정장소 및 복장

조정담당판사 또는 조정위원회는 사건의 실정에 따라 법원 외의 적당한 장소에서 조정을 실시할 수 있다(민조 19조 1항). 조정위원회의 조정위원(7조 6항에 따른 조정위원)이 법원 외의 장소에서 조정사무를 수행하는 경우에는 미리 조정담당판사의 허가를 받아야 한다(2항). 조정은 조정실·심문실 또는 분쟁에 관련된 현장 기타 적당한 장소에서 이를 할 수 있다. 법관 및 법원사무관등은 조정을 할 때 법복을 착용하지 아니할 수 있다(조정예규 14조).

나. 절차의 공개 여부

조정절차는 공개하지 아니할 수 있다. 다만 조정절차를 공개하지 아니하는 경우에도 조정담당판사는 적당하다고 인정하는 자에게 방청을 허가할 수

있다(민조 20조).

다. 기록열람

당사자나 이해관계를 소명한 제3자는 수수료를 납부하고, 기록의 열람·복사, 재판서·조서의 정본·등본·초본의 교부 또는 소송에 관한 사항의 증명서의 교부를 법원사무관등에게 신청할 수 있다(민조규 17조). 개정 민사조정법 38조 1항에서는 민사소송법 163조(비밀보호를 위한 열람 등의 제한)의 준용을 추가하여 조정절차에서도 당사자의 비밀을 두텁게 보호하기 위하여 비밀보호를 위한 열람 등의 제한 방식에 관한 규정을 신설하였다.

라. 조서의 작성 및 송달

조정절차에 참여한 법원사무관등은 조정에 관하여 조서를 작성하여야 하는데(민조 24조), 조정에 관한 조서에는 아래에서 보는 것처럼 ‘조정기일조서’, ‘조정조서’ 및 ‘조정을 갈음하는 결정조서’가 있다.

조정을 하지 아니하기로 하는 결정이 있을 때, 조정이 성립되지 아니한 때, 조정을 갈음하는 결정이 있을 때에는 그 사유(민조 33조 1항)를, 수명법관 또는 상임 조정위원이 조정을 담당할 경우에는 그 취지를(조정예규 19조 2항) 또는 조정기일에 당사자가 구두로 조정을 갈음하는 결정에 대한 이의신청을 한 때에는 그 각각의 취지를 조서에 기재하여야 한다(4항).

조정이 성립된 경우의 조서 작성방식에 관하여는 화해 등 조서의 기재방식에 관한 민사소송규칙 31조의 규정을 준용하므로(민조규 12조의2 3항), 조정기일조서와 조정조서 또는 조정을 갈음하는 결정조서는 따로 작성하여야 한다.

조서의 기재는 조정담당판사의 허가가 있는 때에는 그 일부를 생략할 수 있고(민조 24조), 조정담당판사와 법원사무관등이 기명날인하고 조정담당판사가 지장이 있는 때에는 법원사무관등이 그 사유를 기재하여야 한다(민조규

12조의2 1항).

한편 조정조서 또는 조정을 갈음하는 결정조서를 작성함에 있어 신청 또는 청구의 표시에는 신청 또는 청구를 특정함에 필요한 사항만을 간략하게 기재할 수 있으며, 조정신청서 또는 소장을 복사하여 조서 뒤에 첨부하고 해당 부분을 인용하거나 조정을 갈음하는 결정사항의 산출근거에 관한 계산표를 조서나 결정서 뒤에 첨부할 수 있다(조정예규 19조 1항).

각종 조서의 양식은 다음과 같다.

① 조정기일조서: 수소법원은 [전산양식 A1904], 조정담당판사는 [전산양식 A1905], 조정위원회는 [전산양식 A1906]

② 조정조서: 수소법원은 [전산양식 A1907], 조정담당판사는 [전산양식 A1908], 조정위원회는 [전산양식 A1909]

③ 조정을 갈음하는 결정조서: 수소법원은 [전산양식 A1913], 조정담당판사는 [전산양식 A1914], 조정위원회는 [전산양식 A1915]

법원사무관등은 조정을 하지 아니하기로 하는 결정을 기재한 조서나 조정 불성립 사유를 기재한 조서의 경우에는 그 등본을, 조정을 갈음하는 결정을 기재한 조서나 조정의 성립을 기재한 조서의 경우에는 그 정본을 당사자에게 송달하여야 한다(민조 33조 2항). 그리고 민사조정법 16조의 규정에 의하여 이해관계인이 조정에 참가한 때에는 조정조서 또는 조정을 갈음하는 결정서 정본을 이해관계인에게도 송달하여야 한다(조정예규 20조 3항).

민사조정법 38조 2항 단서가 민사소송법의 규정에 의한 등기우편에 의한 발송송달, 공시송달에 관한 규정은 조정조서의 송달의 경우를 제외하고는 민사조정법에 의한 기일, 기간 및 서류의 송달에 준용하지 아니한다고 하고 있으므로, 조정을 갈음하는 결정서 정본 이외의 서류 송달과 기일의 통지에 대하여도 민사소송법상의 등기우편에 의한 발송송달규정이 준용되지 않는다고 해석될 여지가 있으나, 위 규정의 취지는 조정을 갈음하는 결정서 정본이 등기우편에 의한 발송송달이나 공시송달에 의하여 송달됨으로써 당사자가

위 결정에 대한 이의신청권을 행사하지 못한 채 조정절차가 종료되는 것을 방지하는 데 있으므로 조정을 갈음하는 결정서 정보 이외의 서류(예를 들어 민조 25조, 민조규 2조의2의 규정에 의한 조정신청각하명령서, 민조 26조의 규정에 의한 조정을 하지 아니하는 결정서, 민조규 16조의 규정에 의한 이의신청각하결정서 등) 송달과 당사자에 대한 조정기일의 통지에 대하여는 등기우편에 의한 발송송달이 가능하다(재민 95-1 민사조정절차에 관련된 여러 의문점에 대한 검토의견 11항).

[전산양식 A1905] 조정기일조서

○ 차		○ ○ 법 원	
		조정기일조서	
사 건	20○○머	기 일	20○○. ○. ○. :
판 사		장 소	
		공개여부	공개
법원주사		다음 기일	20○○. ○. ○. :
사건과 당사자의 이름을 부름			
신청인			
피신청인			
출석			
출석			
(예시①) 별지조서와 같이 조정성립			
법원주사		㉠	
판 사		㉠	
(예시②-1) 당사자 사이에 합의가 성립되지 아니하여 조정불성립			
법원주사		㉠	
판 사		㉠	
(예시②-2) 성립된 합의의 내용이 적당하지 아니하다고 인정되어 조정불성립			
법원주사		㉠	

판 사	㉠
(예시③) 당사자 사이에 합의불성립	
판 사	
별지조서와 같이 조정을 갈음하는 결정을 하고 이를 고지	
법원주사	㉠
판 사	㉠
(예시④) 판 사	
사건이 성질상 조정을 함에 적당하지 아니하여 조정을 하지	
아니하는 결정 고지	
법원주사	㉠
판 사	㉠
(예시⑤) 당사자 사이에 합의불성립	
법원주사	㉠
판 사	㉠

민사조정법 26, 27, 28, 30, 32, 33①

(예시①)은 조정성립시의 조서 기재례

(예시②-1)은 민사조정법 27조 1호 조정불성립시의 조서 기재례

(예시②-2)는 민사조정법 27조 2호 조정불성립시의 조서 기재례

(예시③)은 그 기일에 조정을 갈음하는 결정을 한 경우의 조서 기재례

(예시④)는 조정을 하지 아니하는 결정을 한 경우의 조서 기재례

(예시⑤)는 기일 외에서 조정을 갈음하는 결정 등을 하고자 하는 경우의 조서 기재례

※ 이 양식은 조정담당판사가 진행한 조정기일 조서의 예이다. 수소법원이 스스로 조정한 경우에는 사건표시 아래의 ‘판사’ 대신 ‘재판장 판사 ○○○, 판사 ○○○, 판사 ○○○’로 쓰고, 조정위원회 조정의 경우에는 ‘조정장 판사 ○○○, 조정위원 ○○○, 조정위원 ○○○’를 쓴다.

[전산양식 A1908] 조정조서

○ ○ 법 원			
조정조서			
사 건	20○○머		
신 청 인	○○○		
	서울 ○○구		
피신청인	○○○		
	서울 ○○구		
판 사		기 일	20○○. ○. ○. :
		장 소	
법원주사		공개여부	공개
신 청 인			출석
피신청인			출석

다음과 같이 조정성립

조 정 조 항

신청의 표시

신청취지	
신청원인	
	법원주사 ㉠
	판 사 ㉠

※ 직권조정회부의 경우에는 신청인을 원고로, 피신청인을 피고로, 신청의 표시를 청구의 표시로, 신청취지를 청구취지로, 신청원인을 청구원인으로 각각 정정하여 사용한다.

[전산양식 A1913] 조정을 갈음하는 결정 조서

○ ○ 법 원

조정을 갈음하는 결정 조서

사 건 20○○ 가
원 고 ○○○
서울 ○○구
피 고 ○○○
서울 ○○구

재판장 판사 기 일 : 20○○. ○. ○. :
판 사 장 소 :
판 사 공개 여부 : 공개
법원사무관
원고
피고

출석
출석

재판장 판사
수소법원이 다음과 같이 조정을 갈음하는 결정을 하였음을 고지

결 정 사 항

청구의 표시

청구취지
청구원인

법원사무관 ①
재판장 판사 ①

※ 이 결정조서를 송달받은 날부터 2주일 이내에 이의를 신청하지 아니하면 이 결정은 재판상 화해와 같은 효력을 가지며, 재판상 화해는 확정판결과 같은 효력이 있습니다.

※ 조정신청사건의 경우에는, 원고와 피고는 신청인과 피신청인으로, '청구의 표시'란의 '청구'는 '신청'으로 고쳐 쓴다.

마. 조정기일에서의 법원사무관등의 참여 여부

법원사무관등은 조정기일에 참여하여 조정에 관하여 조서를 작성함이 원칙이나(민조 24조 본문), 재판장이 필요하다고 인정하는 경우 법원사무관등을 참여시키지 아니하고 변론기일 및 변론준비기일 외의 기일을 열 수 있다고 규정하고 있는 민사소송법 152조 2항이 민사조정절차에 준용되므로(38조 1항), 조정기관은 법원사무관등을 참여시키지 않고 조정기일을 열 수 있다. 다만 이 경우에도 그 기일이 끝난 뒤에, 조정장의 설명에 따라 조서를 작성하고 그 취지를 덧붙여 적어야 한다.

2. 조정기일과 당사자 출석

가. 당사자의 출석의무

민사조정규칙 6조 1항은 “민사조정법 15조 1항의 규정에 의한 통지를 받은 당사자는 기일에 본인이 출석하여야 한다. 그러나 특별한 사정이 있는 경우에는 대리인을 출석시키거나 보조인을 동반할 수 있다.”라고 규정하여 당사자 본인의 출석의무를 규정하고 있다. 그러나 불출석시 아무런 제재규정이 없어 선언적인 규정에 그치고 있다. 이 점은 가사조정절차에 관하여 가사소송법이 같은 취지의 규정(가소 7조)을 두면서, 조정기일예의 소환을 받은 당사자가 정당한 이유 없이 출석하지 아니하면 “50만 원 이하의 과태료를 부과할 수 있고 구인할 수 있다.”라고 규정(66조)하고 있는 것과 비교된다.

조정담당판사는 가능한 한 미리 특정한 요일을 조정기일로 정하여 각 민사 재판부와 조정사건을 담당하는 법원사무관등에게 통보하여야 하므로(조정예규 13조 1항), 정기적으로 조정을 진행하여야 한다. 같은 조정기일에 다수의 사건을 처리하여야 할 경우에는 시간대를 세분하여 시차제로 기일을 통지함으로써 장시간 대기하는 불편을 덜어주는 것이 바람직하다.

나. 조정신청사건에서의 당사자 불출석

(1) 신청인의 불출석

신청인이 조정기일에 출석하지 아니한 때에는, 다시 기일을 정하여 통지하여야 한다(민조 31조 1항). 새로운 기일 또는 그 후의 기일에 신청인이 다시 출석하지 아니한 때에는 조정신청은 취하된 것으로 본다(2항). 따라서 신청인이 1회 결석한 때에는 반드시 다음 기일을 정하여 통지하여야 하고 곧바로 조정불성립으로 사건을 종결시킬 수 없음에 유의하여야 한다. 또한 2회 불출석에 의한 취하간주는 소의 취하간주와 달리 1월 이내의 기일지정신청은 불가능하며 그 효력이 확정적이다.

피신청인에게 조정기일의 통지가 되지 아니하고 신청인에게만 조정기일의 통지가 된 경우에도 신청인이 2회 불출석하면 조정신청의 취하가 된 것으로 간주되는지 여부에 관하여는 민사조정법 31조는 신청인이 '조정기일'에 2회 불출석한 경우에 조정신청은 취하된 것으로 본다고 규정하고 있고, 15조는 조정기일을 당사자에게 통지하도록 규정하고 있어 피신청인에게 조정기일의 통지가 되지 아니한 경우에는 조정기일은 성립되지 아니한다고 보아야 하므로 그러한 기일에 신청인이 2회 불출석하더라도 조정신청의 취하가 된 것으로 간주할 수 없다(재민 95-1 민사조정절차에 관련된 여러 의문점에 대한 검토의견 6항).

(2) 피신청인의 불출석

피신청인이 조정기일에 출석하지 아니한 경우 조정담당판사는 상당한 이유가 없으면 직권으로 조정을 갈음하는 결정을 하여야 한다(민조 32조).

다. 조정회부사건에서의 당사자 불출석

수소법원이 조정에 회부한 사건의 조정기일에 당사자 쌍방 또는 일방이 출석하지 아니한 경우 조정담당판사는 상당하다고 인정하는 때에는 조정을 갈음하는 결정을 할 수 있다. 그러나 당사자가 출석하지 아니하여 조정기일

을 2회 이상 진행하지 못한 경우 조정을 갈음하는 결정을 하지 아니하는 때에는 조정절차를 종결하고 사건을 수소법원에 다시 회부하여야 한다(민조규 4조 5항). 조정기일에 불출석한 당사자가 원고인지 피고인지는 문제가 되지 아니한다. 이 경우, 원고나 피고 중 일방만이 출석한 경우에는 상대방과 개인적으로 접촉한 사실이 있는지, 출석하지 아니한 이유는 무엇인지 등을 확인하여, 만약 사실상 합의가 된 경우에는 그 합의된 내용으로 조정을 갈음하는 결정을 할 수도 있을 것이다.

3. 조정절차의 진행

가. 사건의 분리·병합

조정기관은 조정사건의 분리 또는 병합을 명하거나 이를 취소할 수 있다(민조 14조의2). 조정절차의 효율적 진행, 판단의 모순 방지, 분쟁의 전면적 해결 등을 위하여 필요한 경우에는 조정기관의 재량으로 사건을 분리·병합할 수 있다. 다만 조정의 결과가 합일적으로 확정되어야 하는 경우에는 분리할 수 없다.

나. 조정기일에서의 소취하의 진술

소의 취하는 서면으로 하여야 하고, 다만 변론 또는 변론준비기일에서는 말로 할 수 있을 뿐이므로(민소 266조 3항), 조정에 회부된 소송사건에 관하여 원고가 변론 또는 변론준비기일이 아닌 조정기일에 말로 소취하를 할 수는 없다. 따라서 원고가 구두로 소취하의 의사표시를 한 때에는 그 자리에서 취하서를 작성하게 하여 제출받도록 한다(조정예규 23조 2항).

그러나 이러한 경우 원고에게 청구의 포기 의사가 있다면, “원고는 이 사건 청구를 포기한다. 소송비용 및 조정비용은 각자가 부담한다.”라는 내용의 조정을 성립시키거나 이를 내용으로 하는 조정을 갈음하는 결정을 할 수도 있다.

조정기일과 변론(준비)기일을 병행하여 진행하는 것이 가능한지, 수소법원 조정회부 후에 제출된 서면을 어떻게 처리하는지 등의 문제에 관해서는 『조정실무』, 102쪽 이하 참조.

다. 조정기일에서의 청구의 포기 또는 인낙의 진술

조정기일에 원고 또는 피고만이 출석하여 청구의 포기 또는 인낙의 진술을 하는 경우에는 청구의 포기 또는 인낙을 내용으로 하는 조정을 갈음하는 결정을 하여 절차를 종결할 수밖에 없다.

4. 진술청취와 사실조사

조정담당판사나 상임 조정위원, 조정위원회는 조정에 관하여 당사자 또는 이해관계인의 진술을 듣고 필요하다고 인정하면 적당한 방법으로 사실을 조사할 수 있다(민조 22조). 2020 개정 민사조정법은 조정절차에서의 증거조사 규정을 삭제하였다.

조정담당판사, 상임 조정위원 또는 조정위원회는 사실조사를 지방법원 판사에게 촉탁할 수 있다(민조규 8조 1항). 조정담당판사나 상임 조정위원은 지방법원 판사에게 분쟁해결에 관하여 이해관계인에 대한 의견의 청취를 촉탁할 수 있다(9조). 촉탁을 받은 지방법원 판사는 상당하다고 인정하는 때에는 소속법원의 조정위원에게 당해 촉탁에 관한 사실조사 또는 의견청취를 하게 할 수 있다(10조). 조정담당판사나 상임 조정위원은 필요한 조사를 공무소 기타 적당하다고 인정하는 자에게 촉탁할 수 있다(11조). 조정위원회는 조정장에게 사실조사를 하게 할 수 있다(8조 2항).

조정담당판사, 상임 조정위원 또는 조정위원회는 필요하다고 인정하는 때에는 소속법원의 조정위원으로부터 전문적 지식·경험에 기한 의견을 청취할 수 있다(민조규 12조). 조정위원의 참여의식과 성취감을 위하여 전문 조정위원의 조사보고나 감정 등을 적극적으로 활용하는 것이 바람직하다.

조정절차에서의 당사자 또는 이해관계인의 진술은 민사소송에서 원용하지 못하도록 제한되어 있다(민조 23조). 이 규정의 입법 취지는 당사자 등이 조정절차에서 조정의 성립을 목표로 한 주장과 양보를 하였을 경우 상대방이 이를 소송에서 원용하지 못하게 하는 데 있다.

조정신청사건의 경우에는 합의안의 도출을 위하여 사실조사가 필요하고 이에 따라 대개 수회 조정기일을 속행하여야 하는데, 이러한 사건을 신청 초기 단계에 조정위원회에 회부하면 기일이 속행될 때마다 교체된 조정위원이 사건내용을 새롭게 파악하여야 하는 번거로움이 있으므로 이와 같은 사건은 조정담당판사가 쟁점을 정리하고 사실조사를 마친 다음 합의안 도출이 가능하게 된 시점에 이르러 사건을 조정위원회에 회부함이 상당하다고 판단되면 조정위원회에 배당하는 것이 적절하다.

제4절 조정절차의 종료

1. 총 설

가. 비송사건절차법의 준용

조정절차는 조정성립 또는 조정불성립으로 종결되는 것이 보편적인 모습 이겠지만, 아래에서 보는 바와 같이 조정신청의 각하결정 등의 형태로 종결되는 경우에는, 민사조정법에 특별한 규정이 있는 때를 제외하고는 그 성질에 반하지 아니하는 한 비송사건절차법 17조(재판의 방식), 18조(재판의 고지), 19조(재판의 취소·변경)가 준용된다(민조 39조).

항고에 관해서도 마찬가지로, 민사조정법에서 즉시항고를 할 수 있도록 명문규정(민조 13조 3항, 21조 3항)을 둔 경우 또는 불복신청을 불허하는 명문규정(4조 3항, 25조 2항, 26조 2항)을 둔 경우 등 특별규정이 있는 경우가 아니면 성질에 반하지 아니하는 한 비송사건절차법 중 항고에 관한 20조(항

고할 수 있는 경우), 21조(항고의 효력), 22조(항고법원의 재판), 23조(항고의 절차)가 준용된다(민조 39조).

나. 절차비용의 부담

조정절차의 비용은 조정이 성립된 경우에는 특별한 합의가 없으면 당사자들이 각자 부담하고, 조정불성립의 경우에는 신청인이 부담한다(민조 37조 1항). 다만 조정신청이 소송으로 이행되었을 때에는 조정비용은 소송비용의 일부로 본다(2항). 또, 소송사건이 조정에 회부된 경우 조정이 성립하거나 조정을 갈음하는 결정이 확정된 때에는 소송비용은 조정절차비용의 일부로 본다. 다만 조정을 갈음하는 결정에 대한 이의신청이 취하된 경우에 있어서 이의신청 이후의 소송비용은 그러하지 아니하다(민조규 16조의2). 물론 민사조정법과 민사조정규칙은 조정절차의 비용부담에 관하여 이와 같이 규정하고 있을 뿐이고, 구체적인 절차비용부담의 재판과 절차비용액 확정절차에 관한 조항을 두고 있지 않고 민사소송법의 관련 조항을 준용하고 있지도 않다. 그러나 민사에 관한 분쟁의 당사자가 법원에 조정을 신청한 사건이 소송으로 이행되지 않은 채 조정신청의 취하 등으로 종료되는 경우 민사소송법에서 정하는 소송비용부담 및 확정절차에 관한 조항을 민사조정절차에 유추적용할 수 있고, 그 조정절차비용에 변호사보수도 산입될 수 있다고 봄이 타당하다. 그리고 그와 같은 방식으로 산정한 변호사보수가 현저히 부당하다고 인정되는 때에는 법원은 ‘변호사보수의 소송비용 산입에 관한 규칙’ 6조에 따라 이를 상당한 정도까지 감액할 수 있다(대법원 2022. 10. 14. 자 2020마 7330 결정).

비송사건절차법의 소송비용액재판에 관한 25조, 관계인에 대한 비용부담 명령에 관한 26조, 비용의 공동 부담에 관한 27조, 비용재판의 불복신청에 관한 28조, 비용 채권자의 강제집행에 관한 29조, 비용의 국고대납에 관한 30조 등의 규정은 그 성질에 반하지 아니하는 한 조정비용에 준용되는 것으

로 해석된다(민조 39조).

2. 조정신청의 취하·각하 등

가. 조정신청의 취하

민사조정법 35조 2항 1호의 규정에 의하여 조정신청의 취하가 인정되고 있지만, 그 방식에 관하여는 법과 규칙에 아무런 규정이 없다. 민사조정법 39조에 의하여 준용되는 비송사건절차법 8조가 신청 기타의 진술은 특별한 규정이 없으면 서면 또는 말로 할 수 있다는 민사소송법 161조를 준용하고 있고, 민사조정법 5조가 조정의 신청은 말로도 할 수 있다고 규정하는 점에 비추어, 말로도 조정신청을 취하할 수 있다고 보는 데에 이견이 없다. 이 경우에는 그 뜻을 조서에 기재하고 피신청인에게는 그 취지를 통지하여 준다. 다만 소의 취하와는 달리 피신청인이 조정절차에서 진술한 경우에도 상대방의 동의는 필요하지 않다는 것이 일반적인 견해이다.

나. 수소법원 조정사건의 소취하

수소법원 조정회부사건의 조정 계속 중에 소가 취하된 때에는 수소법원의 법원사무관등은 조정담당 법원사무관등에게 그 취지를 통지하여야 한다. 원고가 조정기관에 소취하서를 제출한 때에는 조정담당 법원사무관등은 소취하서가 제출된 날 지체 없이 소취하서를 접수담당 법원사무관등에게 인제하여 접수절차를 밟아야 한다. 원고가 구두로 소취하의 의사표시를 한 때에는 그 자리에서 취하서를 작성하게 하여 제출받도록 한다. 조정담당 법원사무관등이 위와 같이 소취하의 통지를 받거나, 직접 소취하서의 접수절차를 밟은 경우에는 기록표지의 좌측 상단에 “20〇〇년 〇월 〇일 소취하”라고 새겨진 고무인을 주인(朱印)한 후 기록송부서에 의하여 사건기록을 수소법원에 송부하여야 한다(조정예규 23조 1항 내지 3항). 위의 설명 중 소취하의 통지 및 사건기록 송부에 관한 부분은 수소법원 조정회부사건을 수소법원이 스스

로 조정하거나 수소법원의 재판장 또는 수명법관이 조정장인 조정위원회에서 조정하는 경우에는 적용하지 아니한다(4항).

다. 조정신청의 각하

당사자에 대하여 조정기일을 통지할 수 없을 때에는 조정담당판사는 결정으로 조정신청을 각하할 수 있고(민조 25조 1항), 이 각하결정에 대하여는 불복신청을 하지 못한다(2항). 조정신청서가 송달불능임에도 신청인이 조정담당판사의 피신청인 주소보정명령에 응하지 아니한 경우 원칙적으로 명령으로 신청서를 각하하고(민조규 2조의2 2항 본문), 이 각하명령에 대하여도 불복하지 못한다(3항). 민사조정규칙 2조의2 2항 단서는 공시송달에 의한 소송진행이 가능하다고 인정되는 때에는 조정이 성립되지 아니한 것으로 사건을 종결시킬 수 있다고 하여, 조정신청서를 각하하여 다시 소를 제기하게 하는 대신 신청인의 편의를 위하여 조정불성립으로 처리하게 함으로써(조정불성립 결정) 소송으로 이행되게 하는 길을 열어 놓았다.

그 이외의 신청 각하결정에 대하여 불복할 수 있는지가 문제 되는데, 명문으로 이를 금하는 규정이 없을 뿐 아니라, 그 결정이 조정절차를 종결시키는 종국적인 결정인 점을 고려하여, 민사조정법 39조에 의하여 준용되는 비송사건절차법 20조의 규정에 따라 항고할 수 있다고 봄이 타당하다.

라. 조정을 하지 아니하는 결정

조정담당판사는 사건의 성질상 조정을 하기에 적당하지 아니하다고 인정하거나 당사자가 부당한 목적으로 조정신청을 한 것임을 인정하는 경우에는 조정을 하지 아니하는 결정으로 사건을 종결시킬 수 있다(민조 26조 1항).

도박자금으로 대여한 돈의 반환을 구하는 조정신청, 단지 자신의 의무이행을 부당하게 회피하거나 소송지연 또는 집행회피만을 목적으로 조정신청을 한 경우 등이 그러한 경우에 해당한다.

그러나 이러한 사유가 밝혀진 경우에도 반드시 조정을 하지 아니하는 결정을 하여야 하는 것은 아니고, 조정불성립으로 처리하거나 경우에 따라서는 조정을 갈음하는 결정을 할 수도 있으므로, 실무상 이 제도가 많이 활용되고 있지는 않다.

조정담당판사가 조정을 하지 아니하는 결정을 하여 사건을 종결시킬 때에는 그 조서의 등본을 당사자에게 송달하여야 하고(민조 33조 2항), 당사자는 이 결정에 대하여 불복신청을 하지 못한다(26조 2항).

3. 조정의 성립·불성립 및 조정을 갈음하는 결정

가. 조정의 성립

(1) 조정성립의 효력

조정은 당사자 사이에 합의된 사항을 조서에 기재함으로써 성립한다(민조 28조). 조정이 성립되고 나면 조정조서 정본을 당사자에게 송달하게 되고(33조 2항) 조정은 재판상의 화해와 동일한 효력이 있다(29조). 따라서 당사자 사이에 조정이 성립되면 종전의 다툼 있는 법률관계를 바탕으로 한 권리·의무관계는 소멸하고 조정의 내용에 따른 새로운 권리·의무관계가 성립한다(대법원 2006. 6. 29. 선고 2005다32814 판결).

(2) 효력의 범위

조정조서에 인정되는 확정판결과 동일한 효력은 소송물인 권리관계의 존부에 관한 판단에만 미친다. 부동산 소유권이전등기에 관한 조정조서의 기판력은 소송물이었던 이전등기청구권의 존부에만 미치고 부동산의 소유권 자체에까지 미치지 않는다. 따라서 부동산 소유자가 부동산 소유권이전등기에 관한 조정의 당사자로서 조정조서의 기판력으로 부동산등기부에 소유명의를 회복할 방법이 없어졌다고 하더라도 소유권이 그에게 없음이 확정된 것은 아니고, 부동산등기부에 소유자로 등기되어 있지 않다고 하여 소유권을 행사하는 것이 전혀 불가능한 것도 아니다. 그러한 소유자는 소유권을 부

인하는 조정의 상대방을 비롯하여 제3자에 대하여 다툼의 대상이 된 부동산이 자기의 소유라는 확인을 구할 법률상 이익이 있다(대법원 2017. 12. 22. 선고 2015다205086 판결). 소송절차 진행 중에 사건이 조정에 회부되어 조정이 성립한 경우 소송물 이외의 권리관계에도 조정의 효력이 미치려면 특별한 사정이 없는 한 그 권리관계가 조정조항에 특정되거나 조정조서 중 청구의 표시 다음에 부가적으로 기재됨으로써 조정조서의 기재내용에 의하여 소송물인 권리관계가 되었다고 인정할 수 있어야 한다(대법원 2007. 4. 26. 선고 2006다78732 판결). 조정조서의 기재방식에 관해서는 위 제3절 참조.

(3) 이의가 제기된 경우의 처리

당사자 일방이 조정조서에 대하여 불복하면서 제출한 서면의 제목이 '이의신청서'이고 조정을 갈음하는 결정에 대한 이의절차를 규정하고 있는 민사조정법 34조가 그 불복신청의 근거 조문으로 기재되어 있다고 하더라도, 조정조서에 대하여는 이의신청이 허용되지 않고 서면에 기재된 불복사유가 조정 자체가 성립된 바 없는데도 마치 조정이 성립된 것처럼 조정조서가 작성되어 있어 조정조서가 무효라는 취지이므로 위 서면은 조정조서의 당연무효사유를 주장하며 한 기일지정신청으로 보아 처리하는 것이 상당하다(대법원 2001. 3. 9. 선고 2000다58668 판결).

나. 신청인의 신청을 전부 받아들이는 조정의 가부

조정담당판사는 조정에 즈음하여 당사자의 진정한 의사를 확인하고, 그 조정조항의 내용이 객관적으로 명확한지, 그 합의내용의 실효성이 확보되어 있는지 등을 검토하여야 한다.

민사조정에 있어서 문제 되는 점의 하나가, 조정제도의 본질과 관련하여 신청인의 신청을 전부 받아들이는 조정(조정을 갈음하는 결정 포함)이 가능한지 여부이다.

원래 재판상의 화해는 상호의 양보가 전제로 되고 있으나, 민사조정은 당

사자의 상호양해를 통하여 조리를 바탕으로 실정에 맞게 분쟁을 해결하는 제도로서(민조 1조 참조) 반드시 당사자 상호의 '양보'가 있어야 하는 것은 아니라고 해석되고, 신청에 의한 조정사건은 다투지 않는 사건이 많은데 신청서 자체에서 "신청비용은 각자 부담한다."라고 기재되어 있는 경우가 대부분이어서 재판상 화해의 경우처럼 신청비용 부담부분에서 신청인이 양보할 여지가 없는 때가 허다한 점을 감안할 때, 조리에 맞는 적절한 해결책이라고 보이면 신청인의 신청을 전부 받아들이거나 전부 배척하는 조정도 가능하다(재민 95-1 민사조정절차에 관련된 여러 의문점에 대한 검토의견 8.).

다. 소송계속 중인 사건의 조정

한편 소송이 계속 중인 사건을 조정에 회부하여 조정이 성립하거나 조정을 갈음하는 결정이 확정된 때에는 소의 취하가 있는 것으로 본다(민조규 4조 3항). 이 경우 조정담당판사는 그 취지를 수소법원에 지체 없이 통지하여야 한다. 다만 수소법원이 스스로 조정한 경우에는 그러하지 아니하다(4항). 조정성립 통지서 양식은 [전산양식 A1918]과 같고, 조정조서의 경정에 관해서는 『조정실무』, 131쪽 이하 참조.

다만 재판상 화해를 조서에 기재한 때에는 그 조서는 확정판결과 동일한 효력이 있고 당사자 사이에 기판력이 생기지만, 그 조서에 확정판결의 당연무효사유와 같은 사유가 있으면 준재심(민소 461조)의 소에 의하지 않고도 그 효력을 다룰 수 있다. 그러므로 당사자 일방이 화해조서의 당연무효사유를 주장하며 기일지정신청을 한 때에는 법원으로서 그 무효사유의 존재 여부를 가리기 위하여 기일을 지정하여 심리를 하고, 무효사유가 인정되지 아니하면 판결로써 소송종료선언을 하여야 한다. 이와 같은 구조는 재판상 화해와 동일한 효력이 있는 조정조서에 대하여도 마찬가지이다(대법원 2001. 3. 9. 선고 2000다58668 판결). 독립한 조정무효확인의 소제기는 불가능하다.

라. 조정을 갈음하는 결정

(1) 조정을 갈음하는 결정을 하여야 하는 경우 및 그 효력

조정이 성립되지 아니한 사건에 대하여는 당사자가 이의신청할 것임이 명백한 경우를 제외하고는 조정을 갈음하는 결정을 하는 것이 원칙이다. 조정 담당판사 또는 조정위원회는 당사자 사이에 합의가 성립되지 아니하였거나 성립된 합의의 내용이 적당하지 아니하다고 인정한 사건에 관하여 상당한 이유가 없으면 당사자의 이익이나 그 밖의 모든 사정을 고려하여 신청인의 신청 취지에 반하지 아니하는 한도에서 직권으로 사건의 공평한 해결을 위한 조정을 갈음하는 결정을 하여야 한다(민조 30조). 특히 당사자가 조정안을 수락하지 않는 이유가 오로지 감정적인 대립에 기인한 경우, 당사자가 사건의 중요한 점에 관하여는 합의에 이르고 있으면서도 지엽적인 의견의 차이로 최종 합의에 이르지 못하는 경우, 당사자가 조정안을 수락하고 있지 않지만 법원의 결정이 있으면 분쟁이 해결될 가능성이 있는 경우, 전문가 조정위원의 관여로 분쟁해결의 기준이 명백히 드러난 경우 등에는 조정을 갈음하는 결정을 하여야 한다.

또, 피신청인이 조정기일에 출석하지 아니한 경우 조정담당판사는 상당한 이유가 없으면 직권으로 조정을 갈음하는 결정을 하여야 하고(민조 32조), 수소법원이 조정에 회부한 사건의 당사자 중 일방 또는 쌍방이 불출석하여 조정기일을 2회 이상 진행하지 못한 경우에는 합의가 성립될 가능성이 없는 것으로 보고 상당한 이유가 없으면 조정을 갈음하는 결정을 한다(조정예규 25조 3항 2호 참조).

조정을 갈음하는 결정양식은 수소법원은 [전산양식 A1910], 조정담당판사는 [전산양식 A1911], 조정위원회는 [전산양식 A1912]와 같다.

조정을 갈음하는 결정이 확정된 경우에는 재판상의 화해와 동일한 효력이 있다(민조 34조 4항). 따라서 예비적·선택적 공동소송에서 조정을 갈음하는 결정에 대하여 일부 공동소송인이 이의하지 않았다면 원칙적으로 그 공동소

송인에 대한 관계에서는 그 결정이 확정될 수 있지만, 조정을 갈음하는 결정에서 분리 확정을 불허하고 있거나 그렇지 않더라도 그 결정에서 정한 사항이 공동소송인들에게 공통되는 법률관계를 형성함을 전제로 하여 이해관계를 조절하는 경우 등과 같이 결정사항의 취지에 비추어 볼 때 분리 확정을 허용할 경우 형평에 반하고 또한 이해관계가 상반된 공동소송인들 사이에서의 소송진행 통일을 목적으로 하는 민사소송법 70조 1항 본문의 입법 취지에 반하는 결과가 초래되는 경우에는 분리 확정이 허용되지 않는다(대법원 2008. 7. 10. 선고 2006다57872 판결). 특히 조정을 갈음하는 결정은 당사자 사이에 합의가 성립되지 아니한 경우에 조정담당판사나 수소법원이 직권으로 당사자의 이익이나 그 밖의 모든 사정을 고려하여 신청취지 내지 청구취지에 반하지 않는 한도에서 사건의 공평한 해결을 위하여 하는 결정이므로(민조 30조), 그 효력이 소송물 외의 권리관계에 미치는지는 더욱 엄격하게 보아야 한다(대법원 2017. 4. 26. 선고 2017다200771 판결).

(2) 한 계

그러나 민사조정법 30조에서 “신청인의 신청 취지에 반하지 아니하는 한도에서”라고 규정하고 있는 데에서 알 수 있듯이, 조정을 갈음하는 결정이 재판으로서의 성질도 가지고 있는 만큼 신청인이 조정절차에서 주장하는 것보다 더 유리한 결정을 하여서는 안 되며, 신청인이 전혀 예상하지 못하는 내용의 결정을 하여서는 안 된다.

또한 재판상 화해의 경우에 있어서 원고가 피고에게 이행을 하기로 하는 화해조항을 둘 수 있는 것과 마찬가지로, 예컨대 점포의 인도를 구하는 조정 신청에 대하여 피신청인이 유익비 또는 임대보증금의 반환을 요구하다가 금액부분에 대하여만 합의가 이루어지지 아니하는 경우와 같이, 조정절차의 진행과정으로 보아 반대급부로서 신청인으로 하여금 피신청인에게 이행하도록 하는 조정안이 전혀 예상 외의 것이 아니라면 피신청인이 별도로 신청(반신청)하지 아니한 경우에도 신청인으로 하여금 피신청인에게 이행을 하도록

하는 내용의 조정을 갈음하는 결정이 가능하다(재민 95-1 민사조정절차에 관한 여러 의문점에 대한 검토의견 9.).

(3) 결정조서와 결정서의 송달

조정을 갈음하는 결정의 경우, 조서 또는 결정서의 정본을 당사자에게 송달하여야 한다(민조 33조).

결정서 정본이 송달불능된 경우의 처리 방법에 대해서는 『조정실무』, 138쪽 이하 참조.

마. 조정의 불성립

조정담당판사는 당사자 사이에 합의가 성립되지 아니하거나 성립된 합의의 내용이 적당하지 아니하다고 인정하는 경우에 조정을 갈음하는 결정을 하지 아니할 때에는 조정이 성립되지 아니한 것으로 사건을 종결시켜야 한다(민조 27조). 이와 같이 의무사항으로 규정한 이유는 신청의 각하, 조정을 하지 아니하기로 하는 결정의 경우와는 달리 사건을 종결시킬 더 이상의 방법이 없기 때문이다.

한편 조정불성립으로 처리한 경우 조정담당판사는 당사자에게 그 내용을 고지하고, 법원사무관등은 조정이 성립되지 아니한 사유를 기재한 조서의 등본을 송달하여야 한다(민조 33조 2항). 별도의 결정서를 작성한 경우에는 그 결정서 등본을 송달하면 된다. 이러한 조정불성립 처리에 대하여 당사자는 불복신청을 할 수 없다.

4. 이의신청 등에 의한 소송으로의 자동이행

가. 이의신청

(1) 이의대상·이의신청권자·신청기간

위에서 본 바와 같이 조정을 갈음하는 결정내용을 조서에 기재한 경우에는 당사자는 조서정본이 송달된 날로부터 2주일 이내에 이의를 신청할 수

있다(민조 34조 1항 본문). 또 조정기일 외에서 조정을 갈음하는 결정을 하고 결정서를 작성하여 그 정본을 송달한 경우에는 이의신청기간이 결정서정본이 송달된 날로부터 기산된다(민조규 15조의2 3항). 조정기일에 조정을 갈음하는 결정을 고지하고 ‘조정을 갈음하는 결정조서’를 작성하는 대신 별도의 결정서를 작성하고 조서에는 “별지와 같이 조정을 갈음하는 결정을 하고 이를 고지”라고 기재한 다음 당사자에게 결정서의 정본을 송달하는 방법도 실무에서 사용되고 있는데, 이 경우의 이의신청기간의 산정기준일에 관하여는 명문의 규정이 없으나, ‘조서정본이 송달된 날’에 준하여 ‘결정서정본이 송달된 날’로 봄이 타당하다.

이 기간은 불변기간이다(민조 34조 5항). 다만 조서정본의 송달 전에도 이의를 신청할 수 있다(1항 단서). 당사자가 조정기일에 구두로 이의신청을 한 때에는 법원사무관등은 조정기일조서에 그 취지를 기재하여야 한다(조정예규 19조 4항).

조정절차에 참가한 이해관계인은 물론, 조정을 갈음하는 결정이 확정되는 경우에 그 효력을 받게 되는 수계인이나 승계인도 이의신청을 할 수 있다고 본다. 이의신청기간은 불변기간이므로 소송행위의 추후보완에 관한 민사소송법 173조가 이의신청에 준용된다(민조 38조 2항). 실무상 신청인이 피신청인의 주소를 허위로 기재하여 송달되게 한 뒤 피신청인의 불출석으로 조정을 갈음하는 결정이 고지되어 이의신청기간이 도과되자, 피신청인이 준재심을 청구하는 경우가 있는데, 이러한 경우의 판결에 대한 불복방법에 관하여 대법원판례(대법원 1978. 5. 9. 선고 75다634 전원합의체 판결 등)가 항소설을 취하고 있는 것을 고려하면 준재심청구를 취하하도록 하고 이의신청을 하도록 할 수 있다.

결정의 일부에 대하여 이의신청이 있는 때에는 그 부분에 한하여 실효된다는 견해도 있으나, 조정을 갈음하는 결정 전부가 실효되는 것으로 보아야 한다.

(2) 이의신청 통지

민사조정법 34조 1항의 기간 내에 이의신청이 있을 때에는 조정담당판사는 이의신청의 상대방에게 지체 없이 이를 통지하여야 한다(민조 34조 2항). 이의통지서의 양식은 [전산양식 A1919]와 같다.

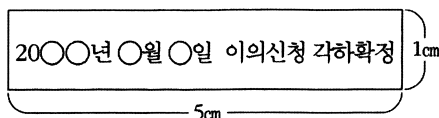
(3) 이의신청의 각하

조정담당판사는 이의신청이 적법하지 아니하다고 인정하는 때에는 결정으로 이의신청을 각하하여야 하고, 이의신청이 적법하지 아니함에도 조정담당판사가 이를 각하하지 아니한 때에는 수소법원이 결정으로 이를 각하한다(민조규 16조 1항). 이의신청서 각하명령이 아님에 유의하여야 한다. 이 각하 결정에 대해서는 즉시항고를 할 수 있고(2항), 이 즉시항고는 집행정지의 효력이 있다(3항).

이의신청이 각하된 경우의 사무처리절차는 다음과 같다.

① 조정을 갈음하는 결정에 대하여 이의신청이 있었으나 조정담당판사 또는 조정장이 이의신청을 각하하여 그 결정이 확정된 경우 조정사건 종국결과로 ‘조정이의신청각하’를 입력한다(조정예규 27조 3항).

② 조정을 갈음하는 결정에 대한 이의신청에 의하여 소송으로 이행된 후 수소법원이 이의신청을 각하하여 그 결정이 확정된 경우 수소법원의 법원사무관등은 민사사건 종국결과로 ‘조정이의신청각하’를 입력하여 사건종결처리를 하고, 사건기록 표지의 좌측상단에 아래와 같은 고무인을 주인(朱印)한 후, 기록송부서에 의하여 사건기록을 조정기관에 송부하여야 한다.



이 경우 사건기록을 송부받은 조정담당 법원사무관등은 기록송부서에 접수인을 찍고 문건으로 전산입력한 후, 기록송부서의 적절한 곳에 조정담당

판사 또는 조정장의 확인인을 받는다. 사건번호는 종전의 것을 그대로 사용하고 조정사건 종국결과로 '조정이의신청각하'를 입력한다(조정예규 27조 1항, 2항).

③ 조정을 갈음하는 결정에 대한 이의신청 각하결정이 확정된 때에는 조정절차의 종결에 따른 공람절차를 밟고, 사건기록은 조정사건기록으로 보존한다(조정예규 30조 3항). 한편 수소법원 조정회부사건을 수소법원이 스스로 조정하거나 수소법원의 재판장 또는 수명법관이 조정장인 조정위원회에서 조정하는 경우에는 조정사건이 소송으로 복귀한 후에 조정을 갈음하는 결정에 대한 이의신청 각하결정이 확정되어 사건기록을 송부받은 때에는 별도의 접수절차를 밟지 아니한다(29조).

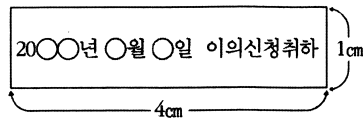
(4) 이의신청의 취하

이의신청을 한 당사자는 당해 심급의 판결이 선고될 때까지 상대방의 동의를 받아 이의신청을 취하할 수 있다. 이 경우 소의 취하에 관한 민사소송법의 규정을 준용하되, '소'는 '이의신청'으로 본다(민조 34조 3항). 이의신청이 취하된 경우에는 이의신청기간 만료일이 조정을 갈음하는 결정의 확정일이 된다.

이의신청이 취하된 경우의 사무처리절차는 다음과 같다(조정예규 26조).

① 사건기록을 관할법원에 송부한 이후에 조정기관에 이의신청 취하서가 제출된 경우에는 법원사무관등은 지체 없이 수소법원에 그 취지를 통지하고 위 취하서를 수소법원에 송부하여야 한다. 이의신청에 따른 소송절차의 진행 중에 이의신청이 취하된 경우 수소법원의 법원사무관등은 민사사건 종국결과로 '조정이의신청취하'를 입력하여 사건종결처리를 하고, 사건기록 표지의 좌측상단에 아래와 같은 고무인을 주인한 후, 기록송부서에 의하여 사건기록을 조정기관에 송부하여야 한다. 사건기록을 송부받은 법원사무관등은 기록송부서에 접수인을 찍고 문건으로 전산입력한 후, 기록송부서의 적절한 곳에 조정담당판사 또는 조정장의 확인인을 받는다. 사건번호는 종전의 것

을 그대로 사용하고 조정사건 종국결과로 '조정의의신청취하'를 입력한다.



② 조정을 갈음하는 결정에 대하여 이의신청이 있었으나 사건기록을 관할 법원에 송부하기 전에 이의신청이 취하된 경우에도 조정사건 종국결과로 '조정의의신청취하'를 입력한다. 조정을 갈음하는 결정에 대한 이의신청이 있었으나 사건기록을 관할법원에 송부하기 전에 상대방의 동의 없는 이의신청취하서가 제출된 경우에는 조정담당 법원사무관등은 기록을 관할법원에 송부하지 아니하고 상대방에게 그 취하서를 송달하여 이의 여부를 확인한다.

③ 이의신청 취하에 따른 공람 및 기록보존절차는 이의신청 각하에 대한 설명과 같다.

(5) 이의신청권의 포기

실무상 금융기관 등에서 사실상 화해 내지 조정이 성립되었음에도 내부 결재 등을 이유로 화해권고결정 내지 조정을 갈음하는 결정을 요청하고 그 결정에 대하여 신속한 확정을 위하여 이의신청권의 포기 제도를 활용하는 경우가 있다.

그런데 화해권고결정에 대한 이의신청권의 포기에 대해서는 민사소송법 229조가 이를 인정하면서 그 절차에 대하여 규정하고 있음에 반하여, 조정을 갈음하는 결정에 대하여는 아무런 규정이 없다. 따라서 조정을 갈음하는 결정에 대하여 이의신청권의 포기가 허용되는지에 관하여는 견해가 나뉠 수 있으나, 조정을 갈음하는 결정에 대하여 이의신청권의 포기를 인정하지 못할 이유는 없으므로 이를 긍정하는 것이 타당하다.

나. 소송으로의 이행 및 복귀의 절차

(1) 소송이행절차

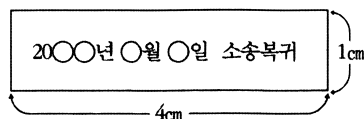
조정신청사건에 대하여 조정을 하지 아니하기로 하는 결정이 있는 경우, 조정이 성립되지 아니한 것으로 사건이 종결된 경우 또는 조정을 갈음하는 결정에 대하여 적법한 이의신청이 있는 경우에는 조정신청을 한 때에 소가 제기된 것으로 본다(민조 36조 1항).

조정신청사건이 위와 같은 사유에 의하여 소송으로 이행된 때에는 법원사무관등은 그 사유가 발생한 날부터 3일 이내에 기록송부서에 의하여 사건기록을 관할법원에 송부하여야 한다. 다만 신청인에 대하여 인지액 또는 송달료 등의 보정을 명하여야 하는 경우에는 그 보정서가 접수된 날부터 3일 이내에 송부하여야 한다. 이와 같이 사건기록을 송부할 때에는 조정절차의 종결에 따른 공람절차를 밟지 아니한다(조정예규 30조 1항). 사건기록을 송부받은 접수담당 법원사무관등은 기록송부서에 접수인을 찍고 소송사건으로 접수하여 민사사건으로 전산입력하고, 사건번호를 부여하여 배당절차를 밟는다. 이 경우 소송기록표지를 별도로 작성하여 이미 첩하여져 있는 조정사건 기록표지 위에 첩하여야 한다(25조 6항).

(2) 소송복귀절차

수소법원에서 조정회부한 사건에서 당사자 쌍방 또는 일방에 대하여 공시송달에 의하지 아니하고는 기일을 통지할 수 없는 때, 당사자 쌍방 또는 일방의 불출석으로 인하여 조정기일을 2회 이상 진행하지 못한 경우에 조정을 갈음하는 결정을 하지 아니하는 때, 조정을 하지 아니하는 결정(민조 26조) 또는 조정불성립으로 사건이 종결된 때, 조정을 갈음하는 결정에 대하여 적법한 이의신청이 있는 때, 우편송달(민소 185조 2항, 187조) 또는 공시송달 이외의 방법으로 당사자 쌍방 또는 일방에게 조정을 갈음하는 결정서 정본을 송달할 수 없는 경우 조정을 갈음하는 결정을 취소한 때에는 조정기관은 조정절차를 종결하고 사건을 수소법원에 다시 회부하여야 한다(조정예규 25

조 3항). 이 경우 조정기관의 법원사무관등은 조정절차가 종결된 날부터 3일 이내에 기록송부서에 의하여 사건기록을 수소법원에 송부하여야 하는데, 이때에는 사건기록표지 좌측상단에 아래와 같은 고무인을 주인하고, ‘일자’란에는 소송복귀일자를 기입하여야 한다(4항, 5항). 이때에는 조정절차의 종결에 따른 공람절차는 밟지 아니한다(30조 1항).



한편 사건기록을 송부받은 수소법원의 법원사무관등은 기록송부서에 접수인을 찍고 문건으로 전산입력한다. 사건번호는 종전의 것을 그대로 사용한다(조정예규 25조 7항). 다만 수소법원이 스스로 조정하거나 수소법원의 재판장 또는 수명법관이 조정장인 조정위원회에서 조정한 사건이 소송으로 복귀한 경우에는 별도의 접수절차를 밟지 아니한다(29조).

수소법원이 조정회부한 것 중, 예컨대 공동불법행위자 수명이 공동피고로 된 손해배상사건과 같이 피고가 2명 이상인 사건에 관하여 조정을 갈음하는 결정을 하였을 경우, 피고 1명만이 이의신청했을 때는 원고와 이의신청한 1명 사이의 사건 부분만 소송으로 복귀되고 원고와 이의신청하지 아니한 나머지 피고들 사이의 사건 부분은 이의신청기간의 도과로 확정되는 것으로 보아야 한다. 따라서 수소법원은 그 부분에 대해서만 재판을 진행해야 한다. 그러나 조정을 갈음하는 결정에서 분리 확정을 불허하고 있거나, 그러지 않더라도 결정 사항의 취지에 비추어 볼 때 분리 확정을 허용할 경우 형평에 반하고 소송진행 통일을 목적으로 하는 민사소송법 70조 1항 본문의 입법 취지에 반하는 결과가 초래되는 경우에는 분리 확정되지 않는다는 점은 앞서 본 바와 같다(대법원 2008. 7. 10. 선고 2006다57872 판결).

(3) 조정결과통지서의 송부

조정사건이 소송으로 이행되는 경우에 조정담당판사 또는 조정장은 수소법원으로 하여금 조정의 경위를 파악하여 소송절차를 보다 효율적으로 진행할 수 있도록 하기 위하여 조정의 진행경과 및 조정실패의 이유 등을 기재한 조정결과통지서[전산양식 A1917]를 수소법원에 송부할 수 있다(조정예규 17조 1항).

가사조정절차에서는 조정기관이 사건기록을 관할가정법원에 송부함에 있어서는 조정장 또는 조정담당판사의 의견을 필수적으로 첨부하여야 하나(가소 61조), 민사조정절차에서는 조정결과통지서의 작성·송부가 임의적 사항으로 되어 있다. 실무상 구체적 이유를 기재한 조정을 갈음하는 결정을 한 경우에는 이를 생략할 수도 있다.

다. 소송으로 이행·복귀된 후의 절차

(1) 인지 추가첨부

조정신청을 한 때에 소가 제기된 것으로 보는 경우 조정신청인은 소를 제기할 때 소장에 붙여야 할 인지액에서 그 조정신청서에 붙인 인지액을 뺀 금액에 상당하는 인지를 보정하여야 한다(민조 36조 2항). 이 경우 조정담당판사는 조정신청인에게 적절한 기간을 정하여 민사조정법 36조 2항에 따른 인지를 보정하도록 명하여야 한다(민조규 16조의4 1항). 조정신청인이 위 기간 이내에 인지를 보정하지 아니한 때에는 조정담당판사는 결정으로 조정신청서를 각하하여야 하고, 이 결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다(2항).

(2) 조정신청사건의 기일 지정

조정신청사건이 조정불성립 또는 이의신청에 의해 소송으로 이행된 때에는 수소법원은 신청인이 처음부터 소를 제기한 것보다 불이익을 받지 않도록 기일지정 등에서 배려하도록 한다(조정예규 17조 2항).

(3) 조정대리인의 소송절차에서의 대리인 자격

조정절차는 원칙적으로 비송사건절차법의 적용을 받는 점에서(민조 39조) 조정절차와 소송절차는 준별되므로, 조정절차에서의 대리인에게 소송절차에서도 대리할 수 있다는 명문의 규정이 없는 현행법상 조정절차에서 판사의 허가를 얻어 대리인이 된 자는 소송으로 이행되거나 소송으로 복귀되면 대리인의 자격을 상실한다고 보아야 한다[재민 95-1 민사조정절차에 관련된 여러 의문점에 대한 검토의견 2.(3)].

(4) 조정참가인, 대표당사자의 소송절차에서의 지위

위에서 본 바와 같이 조정대리인은 소송으로 이행·복귀된 후에 대리인의 자격이 상실되고, 조정참가의 요건 및 절차와 소송참가의 요건 및 절차가 서로 다르므로, 조정참가인도 소송으로 이행·복귀된 후에는 참가인의 지위를 상실하고 소송절차에서 다시 참가절차를 거쳐야 한다.

대표당사자도 소송절차에서 곧바로 선정당사자가 될 수 없고 선정당사자 선정서를 다시 제출하여야 한다.

(5) 조정절차에서의 진술의 소송절차에서의 원용 제한

조정절차에서의 당사자 또는 이해관계인의 진술은 민사소송에서 원용하지 못한다(민조 23조). 따라서 수소법원이 사건을 조정에 회부한 이후에 당사자가 준비서면, 청구취지변경신청서, 반소장 등을 제출한 경우에, 조정기일에서 위 준비서면 등을 진술시킨 경우에도 소송복귀 후 수소법원에서 다시 진술시켜야 한다(재민 95-1 민사조정절차에 관련된 여러 의문점에 대한 검토의견 3.).

(6) 소송으로 복귀된 수소법원 조정사건의 처리

수소법원의 조정을 갈음하는 결정에 대하여 이의신청이 있어 사건이 소송절차로 이행된 경우에는 해당 법원이 계속 사건을 심리함을 원칙으로 한다. 수소법원이 한 조정을 갈음하는 결정에 대하여 이의신청이 제기된 경우 조정을 갈음하는 결정을 한 수소법원이 다시 그 사건을 재판하더라도 전심판여적 성격을 가지는 것은 아니다. 수소법원은 조정을 갈음하는 결정을 함에

있어서 당사자의 불복가능성 등을 고려하여 신중을 기하도록 하고, 조정을 갈음하는 결정에 대해 이의신청이 제기된 경우에는 해당 재판부는 제반 사정에 비추어 그 사건을 계속 심리함이 현저하게 부적당하다고 인정되는 경우 예외적으로 재배당 요구를 할 수 있다.

제5절 조정조항

1. 조정조항의 종류

가. 주된 조항과 종된 조항

주된 조항에는 판결의 주문에 대응하여 확인조항·형성조항·이행조항(금부조항)이 있다. 종된 조항은 다시 부관조항·특약조항·청산조항·관련사건처리조항 및 기타 조항으로 나눌 수 있다. 부관조항은 기본조항인 확인조항·형성조항·이행조항의 실시에 관하여 이를 특히 제한하기 위하여 부가하는 제약을 말하고, 대표적인 것이 기한과 조건이며, 그 밖에 선이행·동시이행·상환이행·대상(代償)금부·기한이익상실(과태약관)·실권조항 등이 있다.

나. 효력조항과 임의조항

효력조항은 조정을 구한 사항에 관한 권리·의무의 확인·발생·변경·소멸·부관(조건·기한·특약 등) 따위를 정하는 것으로 법률상 효력을 갖는 조항이다. 임의조항은, 실체법상 효력에 관계없이 당사자의 의사를 존중하여 특별히 기재하는 조항이다. 예를 들어 법정해제에 관하여 민법 544조의 규정대로의 약속을 조항으로 한다거나, 조정비용은 각자 부담한다고 하여 민사조정법 37조 1항의 규정 내용대로 기재한 조항이 그것이다. 도의적 조항도 임의조항이다.

다. 이행확보조항

이행확보조항은 조정에서 일방 당사자가 일정한 채무의 이행을 약속하는 경우(이행조항) 그 이행을 확실히 하는 조항이다. 금전 분할지급의 경우 기한 이익상실조항, 지연손해금지급조항, 저당권 등의 담보권설정조항, 이해관계인을 참가시키는 보증조항 등이 이에 해당한다.

2. 조정조항 작성 시의 일반적 유의사항

가. 합의내용의 정리·검토

당사자 사이에 합의가 성립되었다고 하여 그 합의내용 전부를 조정조항으로 기재하여서는 안 된다. 합의내용을 정리하고 타당성이 있는지 여부를 판단하여야 한다. 이때 검토하여야 할 사항은, 당사자 사이에 이루어진 합의의 진의를 확인하는 것뿐만이 아니라(성립된 조정조항이 복잡한 경우에는 그 주요내용이 기재된 초안에 쌍방 당사자의 서명·날인을 받아 기록에 첨부하기도 한다), 법률행위의 일반적 유효요건을 충족하고 있는지 여부, 당사자가 자유롭게 처분할 수 있는 권리관계에 관한 합의인지 여부 및 타당성이 있는가 하는 점 등이다. 또한 조정조항으로 해야 할 합의내용과 단순히 당사자 사이의 사실상 양해사항에 불과한 합의내용을 명확히 구분하여야 한다. 조정조항으로 해야 할 합의내용은 원칙적으로 법률상 당사자를 규율·구속하는 효과를 발생시키는 것 즉 효력조항이다. 판결의 주문과는 달리, 그 범위는 사건의 내용에 따라 매우 넓고 당사자의 의사를 존중하여 합의된 신사적 조항이나 정신적 조항으로 해야 할 내용으로 임의조항이 덧붙여지기도 한다.

조정을 주재한 법원 스스로 조정조항의 불명료나 모순 등을 초래하여 조정기일에 이루어진 합의의 효력에 관하여 다툼이 있는 경우 그로 인하여 예상치 못한 불이익을 받게 될 우려가 있는 당사자의 입장과 관점을 충분히 배려하여 합의 당시 상황과 조정에 이르게 된 구체적인 경위 등을 살펴 의미와 효력을 판단하여야 한다. 조정기일에 조정이 성립되지 아니하자 '합의

내용대로 법원이 조정을 갈음하는 결정을 할 것이고 이에 대해 당사자는 이의신청을 할 수 있다.’는 내용을 명시한 합의서를 작성하였고 이후 당사자 일방이 조정을 갈음하는 결정에 대하여 이의신청을 한 경우, 합의서 내용 중 이의신청권을 부정하는 취지의 기재가 포함되어 있어도 이는 조정절차를 주관한 법원이 서로 모순되는 이의신청권 유보에 관한 기재에 대한 별도의 조치를 취하지 않은 것이므로 당사자가 이의신청권을 포기한 것으로 단정해서는 아니 된다(대법원 2022. 1. 27. 선고 2021다291323 판결).

(1) 법률행위의 일반적 유효요건의 충족

합의내용이 사실상·법률상 실현할 수 있는 것이어야 한다. 실현이 불가능 경우에는 무효이다. 여기서 불능은 원시적 불능은 물론, 합의 당시에 이행기에 가능하다고 예상되지 않는 것을 말하고, 불능인지 여부는 사회통념에 따라 판단한다.

토지의 공유물분할을 내용으로 하는 조정조서를 작성하는 경우, 그 토지가 ‘측량·수로조사 및 지적에 관한 법률(현 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률) 시행령’ 60조 1항 1호에 의하여 지적을 정하는 토지라면 제곱미터 미만의 단수 표시 때문에 조정조서 집행이 곤란하게 되는 결과가 생기지 않도록 주의하여야 한다(대법원 2012. 2. 10. 자 2011마2177 결정 참조).

합의내용이 의사표시의 해석에 의하여 어떠한 권리관계 또는 법률관계에 관한 것인가, 또 이에 기하여 이행할 내용이 무엇인가가 확정되어 있거나 확정이 가능하여야 한다.

합의내용은 강행규정이나 법질서 전체를 규율하는 공서양속에 반하지 않는 것이 바람직하다. 그러나 조정조서는 재판상 화해조서와 같이 확정판결과 동일한 효력이 있으므로, 거기에 확정판결의 당연무효 등의 사유가 없는 한 설령 그 합의내용이 강행법규에 위반된다고 하더라도 이는 단지 조정에 하자가 있음에 지나지 아니하여 준재심절차에 의하여 구제받는 것은 별문제로 하고 그 조정조서가 무효가 되는 것은 아니다(대법원 2014. 3. 27. 선고

2009다104960 판결). 따라서 부동산 소유자에 대한 소유권이전등기청구권자가 등기를 하지 않고 있는 사이에 부동산 소유자와 제3자 사이 소송에서 부동산에 관한 소유권이전등기절차를 이행하기로 하는 조정이 성립되고 조정조서에 따라 제3자 앞으로 소유권이전등기가 된 경우 조정조서가 당연히 효력이거나 준재심 절차에 따라 취소되지 않는 한 소유권이전등기청구권자가 종전 소유 명의자에 대한 소유권이전등기청구권을 보전하기 위해서 그를 대위하여 제3자 명의의 소유권이전등기가 원인 무효임을 이유로 말소를 청구하는 것은 조정조서의 기판력에 저촉되어 허용될 수 없다(대법원 2000. 7. 6. 선고 2000다11584 판결, 대법원 2018. 2. 28. 선고 2015다204496 판결, 대법원 2021. 8. 19. 선고 2019다214071 판결 참조).

(2) 당사자가 자유롭게 처분할 수 있는 권리

민사조정에도 사법상의 권리·법률관계에 관하여 인정되는 사적 자치의 원칙에 기한 처분권주의가 그대로 타당하다. 공익성 및 판결의 대세효와의 관계에서 처분권주의가 제한·배제되는 사건(직권탐지주의) 및 형성소송에서는 판결에 의해 정하여야 할 법률효과 및 판결에 의하여 형성되는 창설적 효과를 내용으로 하는 조정조항의 작성은 허용되지 않는다. 따라서 법률관계의 변경·형성을 목적으로 하는 형성소송인 청구이의의 소는 집행권원이 가지는 집행력의 배제를 목적으로 하는 것으로서 그 판결이 확정되더라도 당해 집행권원의 원인이 된 실제법상 권리관계에 기판력이 미치지 않고, 형성판결의 효력을 개인 사이의 합의로 창설할 수는 없으므로, 형성소송의 판결과 같은 내용으로 재판상 화해와 동일한 효력이 있는 조정을 갈음하는 결정이 확정되더라도 판결을 받은 것과 같은 효력은 생기지 않는다(대법원 2023. 11. 9. 선고 2023다256577 판결). 이처럼 성질상 당사자가 임의로 처분할 수 없는 사항에 관하여 조정이 성립하였더라도 그러한 조정조항은 효력이 없어 당연히 무효이고(대법원 2012. 9. 13. 선고 2010다97846 판결), 공유물분할의 소송절차 또는 조정절차에서 공유자 사이에 공유토지에 관한 현물분할

의 협의가 성립하여 그 합의사항을 조서에 기재함으로써 조정이 성립하였다고 하더라도 그 즉시 공유관계가 소멸하고 각 공유자에게 그 협의에 따른 새로운 법률관계가 창설되는 것이 아니고, 공유자들이 협의한 바에 따라 토지의 분필절차를 마친 후 각 단독소유로 하기로 한 부분에 관하여 다른 공유자의 공유지분을 이전받아 등기를 마침으로써 비로소 그 부분에 대한 소유권을 취득하게 된다(대법원 2013. 11. 21. 선고 2011두1917 전원합의체 판결).

(3) 합의의 타당성

당사자 사이에 합의가 성립하여도 그 내용이 위법하다거나 객관적인 사회통념에 비추어 현저히 타당성을 결한 경우에는 그 내용대로 조정조항을 작성할 수 없다. 다만 이 경우에도 당사자가 합의내용에 대하여 그대로 유지하겠다는 입장이 완강한 경우가 아니라면 당사자의 진의를 파악하여 타당성 있는 내용으로 수정하여 합의에 이르도록 유도함이 바람직하다.

나. 조정조항 작성(문장화) 시의 일반적 유의사항

(1) 합의내용을 명확하고 간결하게 기재할 것

조정조항을 작성하려면 먼저 합의내용이 명확한지 여부를 확인하여 만일 애매한 표현이 있으면 명확히 한 다음, 그 합의내용을 육하원칙에 따라 요령 있고 간결하게 기재하여야 한다. 조정조항으로 해야 할 합의내용이 누락되지 않도록 하여야 함은 물론이다. 그런데 너무 표현의 간결성만 강조하게 되면 사후에 해석상 의문이 생길 여지가 있으므로 주의하여야 한다. 또 가능한 한 간명하고 쉬운 용어를 사용하여 법률전문가가 아닌 일반인도 쉽게 그 내용을 이해할 수 있어야 한다. 그리고 조정조항이 너무 장문이면 이해하기 어렵기 때문에 그 내용에 따라서는 항을 나누어 기재하거나 별지로 목록이나 도면을 작성하여 인용하는 것이 필요한 경우도 있다.

(2) 논리적 순서에 따라 조항 수와 배열 순서를 정할 것

일반적으로 조정조항은 논리적 순서에 따라, 조정의 대상이 되는 권리·의

무의 존재 또는 부존재를 확인하는 확인조항과 권리·의무의 발생·변경·소멸 등을 정하는 형성조항을 먼저 기재하고, 그 다음 법률효과로서의 이행조항과 이행조항을 불이행한 경우의 이행확보조항(부판조항)을 기재하며, 마지막으로 청산조항, 비용부담조항을 기재한다. 소송물에 관한 조항과 소송물 외의 권리·법률관계에 관한 조항이 있는 경우에는 전자를 먼저 기재한다. 또 당사자가 여러 명인 경우에는 관계당사자를 명확히 하여야 하고, 당사자별로 조정조항을 두는 것이 바람직한 경우도 있을 것이다. 물론 사안에 따라서는 위와 같은 일반적 기재 순서와 달리 작성할 수도 있겠지만, 그러한 경우에도 조정조항이 불명확하지 않도록 주의하여야 한다.

[기재례]

1. 피고는 원고에게 1억 원을 지급하되, 이를 20〇〇. 3. 31.부터 다 갚는 날까지 매월 말일에 1천만 원씩 분할하여 지급한다.(이행조항)
2. 피고가 현재 지체하고 있는 위 분할금액이 2회분에 달한 때에는 피고는 기한의 이익을 상실하고 원고에게 잔액을 일시에 지급하되, 잔액에 대하여 기한이익상실 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율에 의한 지연손해금을 가산하여 지급한다.(기한이익상실조항 및 지연손해금 지급조항)
3. 원고와 피고는 위 조정조항에서 정한 것 이외에는 어떠한 채권채무(관계)도 없음을 서로 확인한다.(청산조항)
4. 소송비용과 조정비용은 각자 부담한다.(비용부담조항)

(3) 당사자의 표시

조정신청사건에서는 ‘신청인, 피신청인’으로, 조정회부사건에서는 ‘원고, 피고’로 표시한다. 이해관계인이 참가하거나 그 참가를 명한 경우에 그 이해관계인은 이해관계인이나 참가인이라는 표현보다는 ‘조정참가인’으로 표시한다.

(4) 전 문

조정조항 제1항 앞에 당사자가 조정에 이르게 된 경위에 관하여 간략히 기재하여 두는 사례도 있다. 도의조항의 경우 강제집행의 가능성을 둘러싸고

논란이 있을 수 있다고 보아 여기에 함께 기재하는 방식도 고려할 만하다.

[기재례]

당사자 쌍방은 법원의 조정 권고에 따라 다음과 같이 합의하였다.

3. 조정조항의 종류별 작성방법

가. 확인조항

(1) 의 의

확인조항은 일방 당사자가 상대방에 대하여 특정한 권리·의무관계나 법률관계 또는 사실관계에 대하여 그 존재 또는 부존재 등을 확인하고, 이후 이를 다투지 않겠다는 것을 약속하는 조항이다.

확인소송에서의 판결주문에 준하여 생각하면 되지만, 판결에서는 확인의 이익이 없다고 판단되는 경우라도, 조정에서는 그러한 제한을 받지 않고 당사자 사이에 합의가 성립되었고 또 그러한 확인에 의하여 분쟁이 해결되고 장래의 분쟁 재발을 방지할 수 있다면, 확인조항으로 기재한다. 예컨대 과거의 법률관계의 확인, 현재 또는 과거의 사실관계의 확인, 채권 또는 채무의 존재의 확인도 조정조항으로 기재할 수 있다. 채권의 경우에는 동일한 채권 관계가 복수로 존재할 수 있으므로 그 특정에 특히 유의하여야 한다.

(2) 확인의 주체

확인하는 주체는 판결의 경우에는 법원이지만, 조정의 경우에는 당사자이고, 일방 당사자가 상대방에 대하여 의사표시를 하는 형식을 취한다. 원고가 피고에 대하여 토지소유권의 확인을 구하는 소송의 판결주문은 “별지 목록 기재 부동산이 원고의 소유임을 확인한다.”가 되지만, 조정조항에서는 다음과 같이 기재한다.

[기재례]

- ① 피고는 원고에 대하여 별지 목록 기재 부동산이 원고의 소유임을 확인한다.
- ② 피고는 별지 목록 기재 부동산이 원고의 소유임을 인정한다.

(3) 확인의 대상

전형적인 것은 물권의 존재·부존재이다. 물권의 귀속에 관하여 분쟁이 발생한 때에는 물권의 귀속자가 누구인가를 확인하는 조항을 반드시 두어야 한다.

채권의 존재확인(조항의 표현으로는 지급의무의 확인)은 채무부존재확인과 달리, 민사소송에서는 이행판결을 하면 충분하기 때문에 원칙적으로 확인의 이익이 없지만, 조정의 경우에는 반드시 그렇지 않다. 동일한 금액에 관하여 “지급한다.”라는 이행조항이 별항으로 있음에도 첫머리에서 “지급의무가 있음을 확인한다.”라는 확인조항을 기재하는 것은 중복되므로 원칙적으로 이를 피하여야 하지만, 확인조항이 필요한 경우에는 이를 기재하는 것이 바람직하다. 예컨대 신청인이 피신청인에게 대여금 1,000만 원의 지급을 구하는 조정신청을 한 사건에서, 700만 원을 제때에 지급하면 나머지 300만 원의 지급의무를 면제하지만, 불이행한 때에는 1,000만 원과 그 지연손해금을 가산하여 지급한다는 일부 완제 후 면제형으로 조정이 성립한 경우에는, 조정조항의 제1항에서 1,000만 원 지급의무의 확인조항을 두어야 한다.

[기재례]

1. 피고는 원고에 대하여 원고와 피고(양자) 사이에 20〇〇. 1. 17. 체결한 소비대차계약에 기한 1,000만 원의 지급의무(채무)가 존재함을 확인한다.
2. 피고는 원고에게 20〇〇. 9. 20.까지 제1항 기재 금액 중 700만 원을 지급한다.
3. 피고가 원고에게 위 기한 내에 제2항 기재 700만 원을 지급하는 때에

는 원고는 피고에 대하여 나머지 차용금채무를 면제한다. 다만 피고가 제2항 기재 금액의 지급을 지체한 때에는 피고는 원고에게 제1항 기재 1,000만 원 및 이에 대한 20〇〇. 9. 21.부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율에 의한 지연손해금을 가산하여 지급한다.

4. 원고는 나머지 청구를 포기한다.

5. 소송비용과 조정비용은 각자 부담한다.

과거의 법률관계, 과거의 법률행위, 변제 등의 유효·무효 혹은 그 존부, 사실관계(예: 매매계약이 무효인가의 확인, 해제가 유효한가의 확인, 차임 연체가 없었다는 것의 확인) 등도 확인의 대상이 된다. 판례는 원고(주식양수인)가 주식양도인과 그 주식을 발행한 회사 등을 공동피고로 삼아 주주확인 및 주주명의개서청구 등을 구하고 그 진행과정 중 조정이 성립한 사안에서, ‘원고가 피고 회사 주식의 주주임을 확인한다.’는 조정조항은 조정이 성립한 때 비로소 원고가 위 주식을 취득한다는 내용이 아니라, 원고가 주식양도인과 체결한 약정에 따라 이미 그 효력발생일에 그 주식을 취득한 것을 전제로 원고가 주주임을 확인한다는 내용이라고 해석한다(대법원 2019. 4. 25. 선고 2017다21176 판결).

(4) 작성 시 유의점

위에서 지적한 사항 이외에는 확인의 소에 있어서 판결주문의 작성과 동일하다. 확인조항은 확인의 대상이 된 권리 또는 법률관계 및 그 범위·주체를 특정하고 확인의 의사표시가 명확하게 표현되어야 한다.

[기재례]

- ① 피고는 원고에 대하여 별지 목록 기재 부동산이 원고의 소유임을 확인한다.
- ② 피고는 원고에 대하여 원고와 피고(양자) 사이에 20〇〇. 1. 1. 체결한 금전소비대차계약에 기한 1,000만 원의 지급채무가 존재하지 아니함을 확인한다.
- ③ 피고는 원고에 대하여 별지 목록 기재 토지에 관하여 철근콘크리트조 건물의 소유를 목적으로 하는 존속기간 20〇〇. 1. 1.부터 30년의 지

상권이 원고에게 있음을 확인한다.

- ④ 피고는 원고에 대하여 별지 목록 기재 건물에 관하여 원고와 피고 사이에 2000. 1. 1. 체결한 임대차계약에 기한 임차권이 원고에게 있음을 확인한다.

계속적 계약관계 전체를 일괄하여 그 존부 확인을 하는 때에는 다음과 같이 표현하면 족하고 그 계약관계에 기하여 발생하는 개별 권리의무의 주체·내용 등을 일일이 특정하여 표시할 필요가 없다.

[기재례]

피고는 원고에 대하여 양자 사이에 2000. 1. 4. 체결한 어음할인계약에 기하여 2000. 1. 4.부터 2000. 8. 15.까지의 어음할인에 의한 2,000만 원의 지급채무가 존재함을 확인한다.

나. 형성조항

(1) 의 의

형성조항이란 당사자가 자유롭게 처분할 수 있는 권리·법률관계에 관하여 새로이 권리의 발생·변경·소멸의 법률효과를 발생시키는 것을 내용으로 하는 조항을 말한다. 권리발생조항은 매매·임대차·보증 등의 계약을 성립시키는 것이다. 권리변경조항은 청구권의 존재를 전제로 한 이행기의 유예, 임대차계약의 존재를 전제로 한 차임 증감이나 임대기간의 변경 등을 내용으로 한다. 권리소멸조항은 합의해제·상계·채무면제·권리포기 등을 내용으로 하는 조항이다. 형성조항에서는 권리의 주요 요소에 관한 기재를 누락하여서는 안 된다.

판결로써만 창설적 효력이 생기는 형성소송이나 형식적 형성소송은 조정의 대상이 되지 않는 것이 원칙이므로, 그와 같은 내용의 형성조항이 작성되더라도 형성의 효과는 생기지 않는다. 다만 형식적 형성소송이라도 공유물 분할소송에서는 조정이 가능하다(대법원 2013. 11. 21. 선고 2011두1917 전원

합의체 판결). 권리 또는 법률관계가 자유로이 처분할 수 있는 성질의 것이어야 하고, 당사자가 해당 권리 또는 법률관계를 처분하는 권한을 가지고 있어야 하며, 또한 법률행위의 종류·성질·방식·법령 등에 따라서 법률행위로서의 적법유효요건(요식행위인 때에는 해당 방식도)을 구비하여야 한다.

(2) 작성 시 유의사항

원고(임대인 겸 소유자)가 피고(임차인)를 상대로 임대건물의 인도를 구하는 사건에서, 피고가 원고로부터 건물을 매수하기로 하는 합의가 성립한 경우에, 매매계약을 체결한다고 하는 형성조항을 두는 것이 필요하다. 이를 생략한 채 갑자기 이행조항이 나오면, 매매계약의 성립 여부에 관하여 의문이 있을 수 있기 때문이다.

[기재례]

- ① 원고는 20○○. 5. 5. 피고에게 별지 목록 기재 건물을 대금 2,000만 원에 매도하고, 피고는 이를 매수한다.
- ② 1. 피고는 금일 원고에게 별지 목록 기재 부동산을 대금 2,000만 원에 매도하고, 원고는 이를 매수한다.
 2. 원고는 20○○. 5. 15. 피고로부터 제3항 기재 소유권이전등기절차를 이행받음과 동시에 피고에게 제1항 기재 매매대금 2,000만 원을 지급한다.
 3. 피고는 20○○. 5. 15. 원고로부터 제2항 기재 매매대금을 지급받음과 동시에 원고에게 위 부동산에 관한 소유권이전등기절차를 이행한다. 위 등기절차비용은 원고가 부담한다.

권리발생조항은 매매계약·임대차계약·담보권설정계약 등을 조정으로 성립시키는 조항으로서, 당사자·목적물·대금·이행방법(매매계약의 경우)·계약체결일·담보목적물·피담보채권의 내용(담보권설정계약의 경우) 등을 기재하여야 한다. 권리변경조항은 임대차계약의 존재를 전제로 하여 임대보증금·임료를 증액하거나 임대기간을 연장시키는 등 조정으로 계약내용을 변경하는 조항이다. 권리소멸조항은 임대차계약을 장래를 향하여 그 효력을 상실

시키기로 합의해제를 하거나 채무를 면제하여 주는 등 조정으로 권리를 소멸시키는 조항인데, 대상이 되는 권리를 특정하고 변경·소멸의 시기를 명백히 기재하여야 한다.

[기재례]

① 임대차계약이 성립한 경우

1. 원고는 피고에게 별지 목록 기재 토지를 다음과 같은 약정으로 임대하고, 피고는 이를 임차한다.

가. 임대기간: 20〇〇. 7. 1.부터 20〇〇. 6. 30.까지

나. 보증금: 3,000만 원

다. 차임: 월 150만 원. 다만 다음 달 분을 전달 말일에 지급한다.

2. 피고는 20〇〇. 7. 30.까지 위 보증금 중 잔액 2,000만 원(보증금 중 1,000만 원은 이미 지급됨)을 지급한다.

3. 피고가 제2항 기재 보증금의 지급을 지체하거나 제1항 기재 월 차임의 지급을 지체하여 현재 지체하고 있는 금액이 2회분에 달한 때에는 위 임대차계약은 별다른 통지나 최고를 요하지 아니하고 당연히 해지되며, 피고는 원고에게 위 토지상의 일체의 가건물을 철거하고 위 토지를 인도한다.

조정조항 작성 당시에 철거의 목적물을 특정하기 곤란한 사정이 있기 때문에 이를 특정하지 않은 채 제3항에서 ‘일체의 가건물’이라는 표현을 사용한 예이다. 조정에서는 임의이행의 가능성이 크므로 부득이한 경우에는 이러한 불특정한 표현을 사용하여도 무방하다. 다만 피고가 임의로 철거하지 않는 경우 위 조정조항만으로는 철거 강제집행을 할 수 없음은 물론이다.

② 조정참가인이 연대보증채무를 부담하기로 합의한 경우

조정참가인은 원고에 대하여 제1항의 채무를 연대보증한다.

③ 차임을 증액하기로 합의한 경우

원고와 피고는 별지 목록 기재 건물에 관한 차임을 20〇〇. 10. 1.부터 월 150만 원으로 증액하기로 한다.

다만 이 형성조항만으로는 직접 강제집행을 할 수 없다.

④ 상계계약을 하고 그 차액을 지급하기로 합의한 경우

1. 피고는 원고에 대하여 2000. 1. 20.부터 2000. 6. 20.까지 합계 100만 원의 차임 지급채무가 있음을 확인한다.
2. 원고는 피고에 대하여 2000. 5. 1. 피고로부터 매수한 컴퓨터 2대 대금 300만 원의 채무가 있음을 확인한다.
3. 원고와 피고(당사자 쌍방)는 제1, 2항의 채무를 대등액에서 상계한다.
4. 원고는 피고에게 위 차액 200만 원을 2000. 10. 10.까지 지급한다.

다. 이행조항

(1) 의 의

이행조항이란 조정에 있어서 당사자 일방이 상대방 또는 제3자에게 금전의 지급, 물건의 인도, 건물의 철거, 의사의 진술(등기철차) 등과 같이 어떠한 행위를 하거나(작위), 출입금지, 일정 수준 이상의 소음발생금지 등과 같이 어떠한 행위를 하지 않겠다고(부작위) 약속하는 조항을 말한다. 급부조항이라고도 부른다. 실무상 이행조항이 조정조항 중의 대부분을 차지하고 있고, 또한 확인조항이나 형성조항과 달리 이행조항에는 집행력이 있어서 만일 조항대로 이행하지 않으면 그 조항을 기재한 조서를 집행권원으로 하여 강제집행이 행하여질 가능성이 높은 중요한 조항이기 때문에 강제집행 단계에서 지장이 없도록 이행의 주체·목적물·의사표시·이행의 시기와 방법 등이 모두 명확하게 기재되어야 한다.

(2) 이행주체의 특정

조정조항만 보고 누가 누구에게 급부를 하는 것인지를 명확히 하지 않으면 결국 집행당사자가 확정되어 있지 않아 집행권원이 될 수 없다. 이행주체는 통상 신청인(원고)과 피신청인(피고)이 상호 약속하는 것이지만, 급부를 받는 사람을 조정절차에 참가하지 않은 제3자로 정하는 경우에는 조정조항에

제3자의 성명과 주소 및 주민등록번호 등을 명기할 필요가 있다. 다만 이 경우 그 제3자가 직접 조정조서를 집행권원으로 하여 강제집행을 할 수는 없으므로, 그 제3자로 하여금 직접 강제집행을 할 수 있도록 하려면 조정절차에 참가시켜야 한다. 특히 원고와 피고 중 어느 한쪽이 여러 명인 경우에도 급부수령자를 명확히 기재하여 혼란이 없어야 한다.

(3) 이행목적물의 특정

이행목적물이 구체적으로 명확하게 특정되어 있지 않으면 조정조서를 집행권원으로 하여 강제집행을 할 수 없기 때문에 이행목적물을 다른 목적물과 오인할 여지가 없도록 조정조항에 구체적으로 정확하게 표시하여야 한다. 건물인도 조항에서 건물의 실제 현황과 등기부상 표시가 다른 경우에는 현황을 위주로 하여 표시하고 등기부상의 표시는 괄호 등을 사용하여 병기하는 것이 관례이다.

(4) 이행의사의 명확한 표현

작위의무에 대하여는 “지급한다”, “인도한다”라는 표현을 사용하고, “지급함”, “명도함” 등과 같이 “... 함”을 붙이는 표현은 확인조항과 혼동될 우려가 있으므로 사용하지 않는다. 조정조항이 당사자의 의사표시의 기재임에 비추어 “지급하라”, “인도하라” 등의 판결주문에서의 명령형 표현을 사용하여서는 안 된다. 강제조정결정에서도 같다. “... 의무를 부담한다.” 또는 “...의무를 피신청인이 부담한다.”라는 표현은 실체법상 그러한 의무부담에 관한 합의로서의 효력은 인정되지만 이행의사가 명확히 표현된 이행조항이라고 볼 수 없어 집행권원으로 삼을 수 없기 때문에 사용하지 말아야 한다. 부작위채무에 대하여는 “○○를 하지 아니한다.”라고 기재한다.

(5) 금전지급조항

가) 기본형

지급당사자와 그 상대방을 특정하고 금액은 확정금액으로 하고, 이행문언은 “지급한다”로 한다. 단순히 “피고는 원고에게 1,000만 원을 지급한다.”라고

기재하고, 달리 조건·기한·선이행·동시이행에 관한 조항이 없으면 그 취지는 지금 즉시, 무조건 지급한다는 의미이다.

[기재례]

- ① 피고는 원고에게 20〇〇. 8. 5.까지 1,000만 원을 지급한다.
- ② 피고는 원고에게 20〇〇. 8. 5.까지 미합중국 통화 10,000달러를 지급한다.

(4) 금전의 명목

판결에서 금전의 지급을 명할 때에는, 대여금·매매대금·손해금·부당이득금 따위의 금전의 명목은 기재하지 않는다. 판결주문을 무색투명하게 기재하여도 판결이유를 보면 당해 금전의 법률적 성질이 무엇인지를 명확하게 판단할 수 있기 때문이다. 이와 달리 조정조서나 조정을 갈음하는 결정문에는 신청의 표시(신청의 취지와 이유)를 기재한 뒤 조정조항을 기재할 뿐, 조정의 이유를 기재하지 않기 때문에 금전지급을 명하는 조항 안에 금전의 명목을 기재하지 않으면 당해 금전이 무슨 법률적 근거로 지급되는 것인지 알 수 없는 경우가 생길 수 있다. 이 경우에는 당해 금전의 법률적 성질을 알 수 있도록 금전의 명목을 간략하게 기재하는 것이 바람직하다. 다만 소장이나 조정신청서에서 특정한 금전의 지급을 구하고 있고 당사자 사이에 그 금전의 지급에 관하여 합의가 성립한 경우에는, 조정조항에 금전의 명목을 기재하지 않는 것이 실무이다. 조정조서 신청의 표시를 보면 그 금전의 법률적 성질을 알 수 있기 때문이다. 이와 달리 이자, 지연손해금 등은 그 명목을 조정조항에 그대로 기재한다.

라. 종된 조항

(1) 선이행·동시이행조항

조정조항을 작성할 때 피신청인이 채무를 이행하는 데 대하여 신청인도

채무를 이행하여야 하는 때에는 쌍방이 부담할 채무의 내용 및 그 이행의 선후 관계를 명백히 하여야 한다. 즉 신청인이 자신의 채무를 선이행하여야 하는지 혹은 피신청인의 급부와 동시이행을 하여야 하는지 여부를 구별하여 그 이행방법에 오해가 없도록 하여야 한다.

조건·기한·선이행·동시이행의 조항은 보통 주된 조항에 삽입하여 함께 기재한다. 경우에 따라서는 복잡함을 피하기 위하여 단순한 이행조항을 나열하여 기재한 다음 별항에서 동시이행관계 등의 표시를 하기도 한다.

[기재례]

① 선이행조항

피고는 원고로부터 1,000만 원을 지급받은 후(수령한 다음) 원고에게 지급받은 날부터 5일 이내에 별지 목록 기재 건물을 인도한다.

② 동시이행조항

㉮ 피고는 원고로부터 1,000만 원을 지급받음과 동시에(상환으로) 원고에게 별지 목록 기재 건물을 인도한다.

㉯ 1. 피고는 금일 원고에게 별지 목록 기재 부동산을 대금 2,000만 원에 매도하고, 원고는 이를 매수한다.

2. 원고는 20〇〇. 7. 15. 피고로부터 제3항 기재 소유권이전등기절차를 이행받음과 동시에 피고에게 제1항 기재 매매대금 2,000만 원을 지급한다.

3. 피고는 20〇〇. 7. 15. 원고로부터 제2항 기재 매매대금을 지급받음과 동시에 원고에게 위 부동산에 관한 소유권이전등기절차를 이행한다. 위 등기절차비용은 원고가 부담한다.

조정절차에서 피신청인이 동시이행의 항변(예컨대 건물인도를 구하는 사건에서 피신청인이 보증금 상환의 항변을 하는 경우)을 하면서 피신청인도 신청인의 의무불이행에 대비하여 집행권원을 원하는 경우에는 다음과 같이 반대급부에 관한 조항을 조정조항에 포함시키는 것이 바람직하다. 피신청인의 반대신청이나 피고의 반소 제기 여부를 불문한다.

[기재례]

1. 피고는 원고로부터 1,000만 원을 지급 받음과 동시에 원고에게 별지 목록 기재 건물을 인도한다.
2. 원고는 피고로부터 위 건물을 인도 받음과 동시에 피고에게 1,000만 원을 지급한다.

(2) 기한이익 상실조항

기한이익 상실조항은 분할지급약정을 하여 채무자에게 기한의 이익을 부여하면서 그와 더불어 만일 채무자가 그 약속을 지키지 않은 때에는 기한의 이익을 상실하고 일시에 변제하여야 한다는 내용을 정한 이행확보조항이다.

[기재례]

피고가 현재 지체하고 있는 위 분할금이 2회분에 달한 때에는 기한의 이익을 상실하고, 원고에게 잔액을 일시에 지급한다.

채권자는 분할금의 연체횟수에 관하여 1회라도 연체한 때를 희망하는 경우가 많지만, 실무에서는 연체횟수를 2회로 하는 경우가 많다. 1회 연체만으로 기한의 이익을 상실시키는 것은 채권자에게 유리할지는 몰라도 채무자에게 너무 가혹하고, 채무자에게 지급능력과 의사가 있음에도 착오 등으로 이행을 도과하는 수도 있기 때문이다.

기한이익 상실조항에는 일정한 사유가 발생하면 어떤 통지나 최고 없이 채무자가 갖는 기한의 이익을 당연히 상실시키는 당연상신행과 일정한 사유가 발생하면 기한의 이익을 상실시킬 것인가 여부의 결정권을 채권자에게 부여하여 채권자가 채무자에게 잔액을 일시에 청구하여 기한의 이익을 상실시키는 의사표시를 한 때에 비로소 기한의 이익을 상실시키는 청구상신행의 두 가지가 있다.

[기재례]

① 당연상실행

피고가 ~ 지급을 지체한 때에는 (당연히) 기한이익을 상실하고, 즉시 원고에게 잔액을 지급한다.

② 청구상실행

피고가 ~ 지급을 지체한 때에 원고는 기한이익을 상실시킬 수 있고, 그 통지를 받으면 즉시 원고에게 잔액을 지급한다.

(3) 지연손해금지급조항

일방 당사자가 상대방에게 금전을 지급하기로 합의하는 이행조항에서 일정한 비율의 지연손해금의 지급약정이 있으면 지급의무자의 기한 내 지급에 동기를 부여하게 된다. 이 조항이 없더라도 법정이율에 의한 지연손해금은 당연히 가산된다는 견해도 있을 수 있지만, 조정조항에 관례적으로 “나머지 청구를 포기한다.”라는 조항이 들어가는 경우가 대부분이고 이러한 권리포기 조항이 있는 이상 법정이율에 의한 지연손해금이 당연히 가산된다고 볼 수는 없다. 조정조항에서 지연손해금지급조항을 누락하는 것은 당사자의 의사에 배치될 수가 있으므로 가급적 넣어주는 것이 바람직하다.

[기재례]

피고는 원고에게 20〇〇. 8. 31.까지 9,000만 원을 지급한다. 만일 피고가 위 지급을 지체하면 20〇〇. 9. 1.부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율에 의한 지연손해금을 가산하여 지급한다.

(4) 실권조항

실권조항은 정지조건의 일종으로 예컨대 매매계약의 존속을 확인하는 조항에 덧붙여 매수인에게 일정한 채무불이행(예컨대 잔금 지급 연체)이 있는 경우 매매계약은 당연히 해제되고 매수인은 매매목적물을 반환한다는 조항과 같은 것이다. 채권자의 특정 행위(최고·통지·해제의사표시) 등이 없이도 권리·법률관계가 당연히 변동(당연해제 등)되는지 여부를 정확히 기재하여야 한다.

[기재례]

① 당연해제

피고가 ~ 지급을 지체한 때에 이 사건 매매계약은 당연히 해제되고
피고는 원고에게 즉시 이 사건 기계를 인도한다.

② 최고는 필요 없지만 해제의사표시는 필요로 하는 경우

피고가 ~ 지급을 지체한 때에 원고는 계약의 이행을 최고하지 않고도
이 사건 매매계약을 해제할 수 있다.

(5) 권리포기조항과 포괄적 청산조항

조정조항에는 권리포기조항과 포괄적 청산조항이 포함된다.

[기재례]

① 권리포기조항

원고는 나머지 청구를 포기한다.

② 포괄적 청산조항

원고와 피고는 양자 사이에 위 각 조항에서 정한 것 이외에는 아무런
채권채무가 없음을 서로 확인한다.

위 ①의 경우 “...나머지 청구...”라는 표현은 해당 사건에서 분쟁의 대상이 된 권리관계 중 다른 조정조항에서 합의되지 않은 청구권을 의미하고, 위 ②의 경우는 해당 사건에서 분쟁의 대상이 된 권리관계 이외의 모든 법률관계에 관하여도 서로 아무런 채권·채무가 없다는 내용이다.

권리포기조항은 소송법상 청구의 일부포기가 아니라 채권적 청구의 경우에 실제법상 채무면제계약의 의미를 갖는 형성조항이고, 포괄적 청산조항은 확인조항이다. 따라서 양자는 하나의 조정에서 병존할 수 있다.

당사자의 희망이 있는 한 위 조항들은 가급적 기재하여야 한다. 그러나 포괄적 청산조항을 포함하여 조정조항을 작성하는 경우에는 나중에 이 조항의 효력 및 범위에 관하여 자신의 진의에 반한다고 이의를 제기할 여지가 있으므로 당사자의 의사를 충분히 확인하여야 한다.

[기재례]

- ① 해당 사건에 관하여만 청산조항을 두는 경우
원고와 피고는 양자 사이에 20〇〇. 2. 1. 자 대여금에 관하여 위 각 조항에서 정한 것 이외에는 어떠한(아무런) 채권채무도 존재하지 아니함을 서로 확인한다.
- ② 모든 사건에 관하여 청산조항을 두는 경우
원고와 피고는 양자 사이에 위 각 조항에서 정한 것 이외에는 어떠한(아무런) 채권채무도 존재하지 아니함(없음)을 서로 확인한다.

포괄적 청산조항을 두지 않을 경우 주의할 점은 소송물 이외의 권리관계에도 조정의 효력이 미치려면 특별한 사정이 없는 한 그 권리관계가 조정조항에 특정되거나 조정조서 중 청구의 표시 다음에 부가적으로 기재됨으로써 조정조서의 기재내용에 의하여 소송물인 권리관계가 되었다고 인정할 수 있어야 한다.

(6) 도의조항

조정조항 중에는 당사자에게 도의적인 책임이 있음을 확인하거나 윤리적인 준수를 기대함으로써 사후 분쟁의 발생을 방지하는 조항, 당사자에게 심리적인 부담을 주기 위한 조항 등 이른바 도의적 사항이 포함되는 경우가 있다. 도의적 조항은 임의조항으로서 법률적 효력이 없고 강제집행의 가능성을 둘러싸고 나중에 논란에 휩싸일 염려가 있으므로 가급적 조정조항에 포함시키는 일은 피하여야 한다. 다만 당사자가 굳이 원하고 그것이 당사자에게 도의적 책임감을 갖게 하여 다른 조정조항의 이행과 향후 분쟁의 재발 방지에 도움이 된다면, 단순히 그 조항이 법률상 효력이 없다는 사유만으로 당사자의 희망을 거부할 필요는 없다. 부작위채무와 유사한 내용의 도의조항은 강제집행과의 관계상 논란의 소지가 있으므로 다른 조정조항과 구별하여 별도의 항으로 하거나 도의조항에 불과하다는 점을 조정조항에서 밝히거나 조정조항 앞에 전문으로 둬으로써 향후의 분쟁 재발을 방지하여야 한다.

[기재례]

- ① 원고와 피고는 이 사건이 위와 같이 원만히 해결되었음을 상호 확인하고, 향후 형제간의 분쟁을 일체 청산하고 형제간의 우의를 더욱 돈독히 할 것을 다짐한다.
- ② 피고는 원고에게 20〇〇. 1. 16.과 같은 해 2. 3. 두 차례에 걸친 집단행위로 인하여 이 사건 공사에 지장을 초래한 점에 대하여 사과한다.
- ③ 피고는 원고에 대하여 피고의 서비스에 미흡한 점이 있었다는 원고의 말을 겸허하게 받아들여 앞으로 피고의 서비스 증진에 더욱 노력한다.
- ④ 원고와 피고는 쌍방의 가족을 포함하여 이웃사촌임에도 이 사건 분쟁이라는 불행한 사태에 이르게 된 것을 진지하게 반성하고 앞으로는 서로 상대방의 생활에 일체 간섭하지 않으며 이웃으로서 사이 좋게 생활할 것을 약속한다.
- ⑤ 원고와 피고는 제1항의 약속이 성립한 것을 거울 삼아 서로 상대방의 과거 언동에 관하여 앞으로 일체의 비방이나 증상을 하지 않을 것을 약속한다.

(7) 비용부담조항

조정비용을 각자 부담한다고 기재하는 것은 임의조항에 불과하지만, 당사자 사이에 이와 다른 합의가 있어 이를 기재하면 이는 효력조항이 된다. 원고 전부승소 취지의 강제조정결정을 하는 경우 조정비용을 피고(피신청인)가 부담하는 결정도 가능하므로, 필요한 경우 활용할 수 있다.

[기재례]

- ① 조정신청사건의 경우
조정비용은 각자 부담한다.
- ② 조정회부사건의 경우
 - ㉗ 소송비용과 조정비용은 각자가 부담한다.
 - ㉘ 소송비용과 조정비용은 피고가 부담한다.

(8) 관련사건처리조항

조정사건에서 이와 관련 있는 다른 사건의 처분에 관한 합의를 하는 경우

가 있는데 이러한 합의도 조정조항에 기재한다. 별건의 소송 또는 신청사건의 취하, 보전처분의 집행취소신청, 보전처분이나 강제집행정지사건의 보증에 관한 담보취소에 대한 동의, 형사사건의 고소취소에 관하여 합의가 성립한 경우가 그 예이다. 이러한 합의는 해당 사건에서 한 것이 아니라, 별개 사건인 조정사건에서 한 것이기 때문에, 그러한 합의가 있었다 하여 곧바로 취하 등의 효력이 발생하는 것은 아니라고 보는 것이 다수의 견해이다. 그리고 이와 같은 관련사건 처리조항은 그 전제로 다른 조정조항의 이행이 조건으로 붙어 있는 조건부 조항인 경우도 많다.

[기재례]

① 원고는 서울중앙지방법원 20○○가합2034 손해배상(기)청구사건을 취하하기로 하고, 피고는 이에 동의한다.

다만 위와 같은 합의가 되더라도 이는 재판 외의 소취하의 합의이고 이로써 곧 당해 사건에 대하여 소취하의 효력이 생기는 것은 아니기 때문에 다시 소취하서를 작성하여 제출하는 것이 필요하다. 원고가 합의에 따라 취하를 하지 않을 경우에, 피고가 위 소송에서 위와 같은 소취하 합의의 성립을 항변으로 주장하면 법원은 권리보호의 이익이 없다는 이유로 소를 각하하게 될 것이다.

② 원고는 피고에 대하여 서울중앙지방검찰청에 제기한 사기사건(20○○형제1234호)의 고소를 취소하기로 한다.

③ 원고는 피고로부터 제1항 기재 금원을 지급받으면 지체 없이 피고 소유 부동산에 대하여 한 가압류(서울중앙지방법원 20○○카단1234)의 해제(취하)신청을 한다.

④ 피고는 원고에 대하여 원고가 서울중앙지방법원 20○○카기1234호 강제집행정지신청사건에 관하여 제공한 담보의 취소에 동의하고, 그 취소결정에 대한 항고를 하지 아니한다.

(9) 사실증명조항

조정기일을 여는 자리에서 당사자가 직접 금전을 변제하면서 이를 조서에 기재하여 줄 것을 희망하면 그 변제사실을 증명하는 의미에서 이를 조정조항에 포함시킨다. 이는 조정조항 중 변제방법(지급방법)란에 기재한다.

[기재례]

1. 피고는 원고에 대하여 20〇〇. 3. 15. 금전소비대차계약에 기한 1,000,000원의 잔존채무로서 1,100,000원(원금 1,000,000원, 이자 100,000원)의 지급채무가 있음을 확인한다.
2. 피고는 원고에게 제1항의 금원을 오늘 조정기일이 열린 자리(조정위원회 석상)에서 지급하고, 원고는 이를 수령하였다.

(10) 특약조항

특약조항이란 실체법의 규범을 배척 또는 보충하거나 실체법에 정해지지 아니한 사항을 정한 조항을 말한다. 당사자가 자유롭게 처분할 수 있는 권리·법률관계에 관하여 강행법규나 공서양속에 반하지 않는 한 허용된다.

[기재례]

피고는 별지 목록 기재 부동산에 관한 20〇〇. 1. 1. 이후의 제세공과금을 부담한다.

마. 향후분쟁종식조항

[기재례]

1. 피고는 원고에게 20〇〇. 5. 31.까지 지참 또는 송금하여 6,000만 원을 지급하되, 만일 피고가 위 기일까지 위 금액을 지급하지 않는 경우에는 그다음 날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율에 의한 지연손해금을 가산하여 지급한다.
2. 원고는 나머지 청구를 포기하고, 피고는 원고에 대하여 향후 이 사건 주택 건축공사로 인한 하자보수 등 일체 이의를 제기하지 아니한다.
3. 조정참가인은 피고에 대하여 이 사건 주택 건축공사로 인한 일체 이의나 청구를 하지 아니한다.
4. 원고는 피고로부터 제1항 기재 금원을 지급받으면 지체 없이 피고 소유 부동산에 대하여 한 가압류(서울중앙지방법원 20〇〇카단1234)의 해제신청을 한다.
5. 소송비용과 조정비용은 각자 부담한다.

기타 소송유형별 조정조항 작성시 유의사항 등에 관해서는 『조정실무』, 618쪽 이하 참조.